Aktenzeichen:
7 O 44/16

Landgericht Mannheim

Im Namen des Volkes

Urteil

In dem Rechtsstreit

gegen

wegen Patentverletzung

hat das Landgericht Mannheim - 7. Zivilkammer - durch auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 30.09.2016 für Recht erkannt:

I. Die Beklagte wird verurteilt,

1. es bei Meldung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000 – ersatzweise Ordnungshaft – oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlungen bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an ihrem jeweiligen Geschäftsführer zu vollstrecken ist, zu unterlassen

   Multiplexgerät zum Multiplexen von Datenpaketen mit verschiedenen zugeordneten Prioritäten, mit: Mitteln zum Empfangen von Datenpaketen; Mitteln zum Bedienen eines Warteschlangenspeichers für jede unterschiedliche Priorität von Datenpaketen; Mitteln zum Zusammensetzen einer Gruppe der Datenpakete, wobei durch Auswählen von Datenpaketen aus einem oder mehreren der Warteschlangenspeicher nach einer ersten Regel ein erster Teil der Gruppe mit Datenpaketen befüllt wird und durch Auswählen von Datenpaketen aus einem oder mehreren der Warteschlangenspeicher nach einer zweiten Regel ein zweiter

Teil der Gruppe mit Datenpaketen befüllt wird; Mitteln zum Übertragen der Gruppe,

in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen,

wenn das Multiplexgerät weiterhin Mittel umfasst zum Anpassen der Größe des ersten und zweiten Teils gemäß der durch Daten in jedem Warteschlangenspeicher relativ zu einem Verzögerungskriterium für den jeweiligen Warteschlangenspeicher erfahrenen Verzögerung

– Patentanspruch 7 –

2. Die Beklagte wird verurteilt,

der Klägerin in einer gesonderten Aufstellung, hinsichtlich der Angaben a und b unter Vorlage von Rechnungen oder Lieferscheinen oder Quittungen, darüber Angaben zu machen, in welchem Umfang sie die in Unterziffer 1 bezeichneten Handlungen begangen hat, und zwar unter Angabe

a) der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse, sowie der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderen Vorbesitzer,

b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen, den jeweiligen Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer,

c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen, der jeweiligen Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,

d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet, im Falle von Internet-Werbung der Domain, den Zugriffszahlen und den Schaltungszeiträumen,

e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,

wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nicht-gewerblichen Abnehmer und Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von ihr zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist.

II. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die in Ziffer I.1. bezeichneten Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

III. Die Beklagte wird verurteilt,

1) die vorstehend unter Ziffer I.1. bezeichneten, im Besitz gewerblicher Dritter befindlichen Erzeugnisse aus den Vertriebswegen zurückzurufen und endgültig zu entfernen,

2) die in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz und/oder Eigentum befindlichen, vorstehend zu Ziffer I.1. bezeichneten Erzeugnisse auf eigene Kosten zu vernichten oder nach ihrer Wahl an einen von ihr zu benennenden Treuhänder zum Zwecke der Vernichtung auf ihre – der Beklagten – Kosten herauszugeben (alternativ an einen zur Vernichtung bereiten Gerichtsvollzieher).

IV. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

V. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

VI. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von jeweils € 800.000,00 in Ziffern I.1 (Unterlassung), III.a) und b) (Rückruf/Entfernung), in Höhe von € 50.000 in Ziffer I.2 (Auskunft/Rechnungslegung) und in Höhe von 120% des jeweils zu vollstreckenden Betrages in Ziffer V. (Kosten).

Tatbestand

Die Klägerin nimmt die Beklagte wegen behaupteter Verletzung des Patents EP 1 815 647 B1 auf Unterlassung, Auskunft/Rechnungslegung, Vernichtung und Rückruf/Entfernung aus den Vertriebswegen in Anspruch und begehrt die Feststellung einer Schadensersatzpflicht.

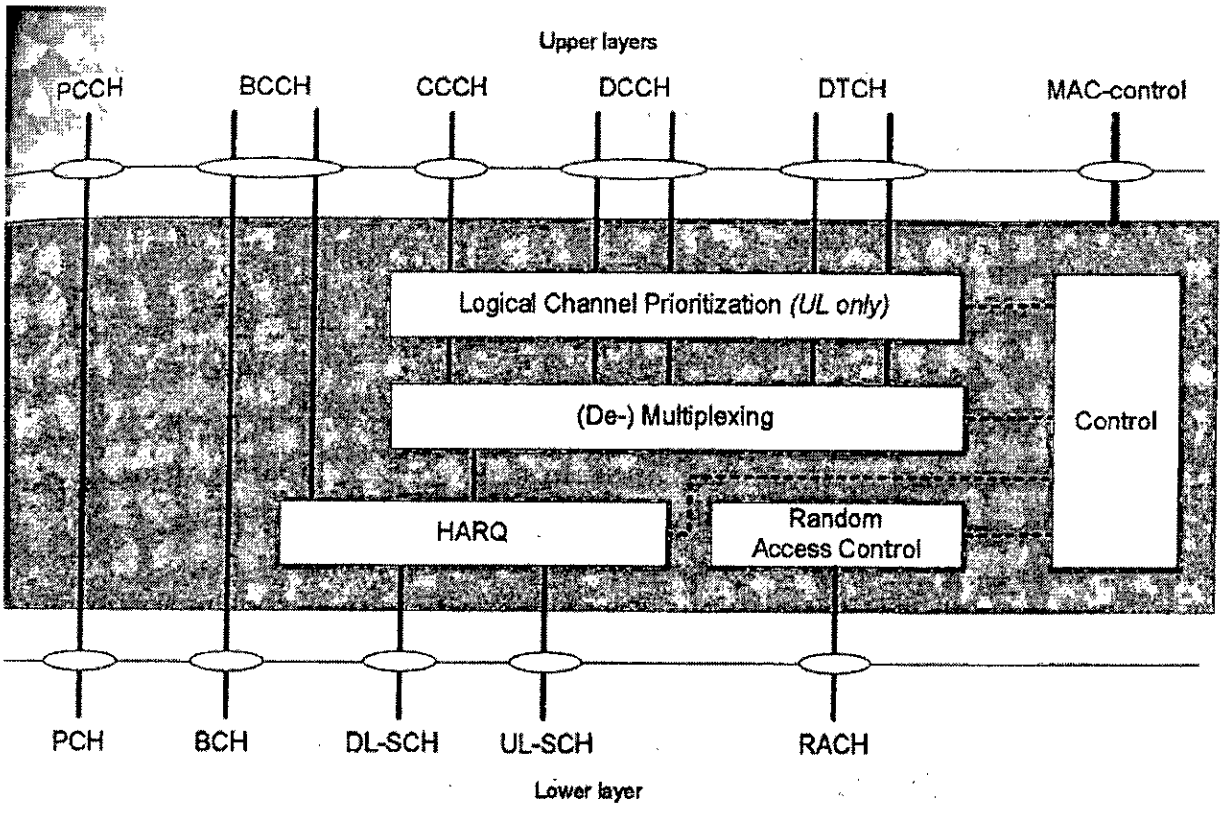
Die Klägerin ist ein weltweit operierendes Elektronikunternehmen, das u.a. auf dem Gebiet der Mobilfunktechnologie zahlreiche Patente hält. Die Beklagte vertreibt in der Bundesrepublik Deutschland u.a. LTE-fähige Mobiltelefone unter der Marke „X". Sie steht seit dem 29.08.2016 im mittelbaren Alleinbesitz der A Ltd. (im Folgenden A), die von der chinesischen Tinno Mobile Technology Corp. kontrolliert wird. Davor hielt die A mittelbar 51 % der Anteile an der Beklagten. Die A ist zugleich die Alleingesellschafterin der französischen X SAS, die die Webseite www.Xmobile.com hostet, unter der der Internetauftritt der einzelnen X-Landesgesellschaften erreichbar ist. Auch die Webseite der Beklagten wird unter dieser Domain unter der genannten Adresse gehostet.

Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des Patents EP 1 815 647 B1, welches ein Verfahren und eine Vorrichtung für das Zusammensetzen von Datenpaketen zum Gegenstand hat. Die Erteilung des am 04. November 2005 angemeldeten Patents wurde am 12. August 2009 veröffentlicht. Der deutsche Teil des Klagepatents (im Folgenden „Klagepatent") steht unter DE 60 2005 016 008.6 in Kraft. Der unabhängige Anspruch 7 des Klagepatents hat – in der Verfahrenssprache – folgenden Wortlaut:

> Multiplexing apparatus (300) for multiplexing data packets having different assigned priorities, comprising:
>
> means (30, 40) for operating a queue store (50) for each different priority of data packet;
>
> means (60, 80) for assembling a group of the data packets wherein a first portion (90) of the group is populated with data packets by selecting data packets from one or more of the queue stores (50) according to a first rule and a second portion (95) of the group is populated with data packets by selecting data packets from one or more of the queue stores (50) according to a second rule;
>
> means (100) for transmitting the group; and characterized by
>
> means (110) for adapting the size of the first and second portions (90, 95) according to the delay experienced by data in each queue store (50) relative to a delay criterion tor the respective queue store (50).

Wegen des weiteren Inhalts des Klagepatents, insbesondere wegen der Beschreibung und der zugehörigen Figuren, wird auf die Patentschrift Bezug genommen, die als Anlage K C1 zu den Akten gereicht wurde.

Im Mobilfunkbereich gibt es verschiedene Standards, die die Anforderungen niederlegen, die u.a. Mobilstationen erfüllen müssen, um über den jeweiligen Standard am Mobilfunkverkehr teilnehmen zu können. Die Anforderungen des sog. LTE(Long Term Evolution)-Mobilfunkstandards sind u.a. in dem Standard-Dokument 3GPP TS 36.321 V8.5.0 (2009-3) enthalten (im Folgenden kurz „Standard"), das als Anlage K C2 vorliegt. In dem Standard ist das Protokoll der sog. MAC (Medium Access Control)-Protokollschicht beschrieben, das von den Mobilstationen für die Nutzung der Luftschnittstelle des LTE-Standards, des sog. E-UTRA, befolgt werden muss. Auf der MAC-Ebene werden sog. Transportkanäle für die spätere Übertragung von Daten über die sog. physikalische Schicht verwaltet. Die MAC-Schicht ist – wie sich aus Abschnitt 4.4 des Standards ergibt – dazu in der Lage, durch Multiplexing MAC-Datenpakete (sog. MAC-SDUs), die ihr aus einem oder mehreren logischen Kanälen zugeführt werden, in Transportblöcken für die weitere Übersendung der Daten an die physikalische Schicht über die Transportkanäle zusammenzustellen. Die Zusammenhänge zwischen MAC-Schicht, den logischen Kanälen, den Transportkanälen und den weitergereichten Datenpaketen mit ihrer Zusammenstellung in Transportblöcke für die Weiterleitung über die Transportkanäle zeigt schematisch die nachstehend eingeblendete Figur 4.2.1.1 aus dem Standard:



In der eingeblendeten Figur sind die logischen Kanäle in dem mit „*Upper Layers*" überschriebenen Bereich und die Transportkanäle in dem mit „*Lower Layer*" gekennzeichneten Bereich schematisch erfasst, während die MAC-Schicht zwischen diesen beiden Bereichen liegt. Einer der Transportkanäle ist der sog. gemeinsam genutzte Uplink-Kanal UL-SCH (Uplink Shared Channel).

Nach Abschnitt 4.4 des Standards hat die MAC-Schicht auch die Funktion, unterschiedliche Priorisierungen zwischen unterschiedlichen logischen Kanälen einer Mobilstation zu handhaben. Das Verfahren für die logische Kanalpriorisierung beim Transportkanal UL-SCH ist in Abschnitt 5.4.3.1 des Standards niedergelegt, der im Folgenden auszugsweise wiedergegeben wird:

The Logical Channel Prioritization procedure is applied when a new transmission is performed.

RRC controls the scheduling of uplink data by signalling for each logical channel: *priority* where an increasing *priority* value indicates a lower priority level. *prioritisedBitRate* which sets the Prioritized Bit Rate (PBR). *bucketSizeDuration* which sets the Bucket Size Duration (BSD).

The UE shall maintain a variable Bj for each logical channel j. Bj shall be initialized to zero when the related logical channel is established, and incremented by the product PBR × TTI duration for each TTI, where PBR is Prioritized Bit Rate of logical channel j. However, the value of Bj can never exceed the bucket size and if the value of Bj is larger than the bucket size of logical channel j, it shall be set to the bucket size. The bucket size of a logical channel is equal to PBR × BSD, where PBR and BSD are configured by upper layers.

The UE shall perform the following Logical Channel Prioritization procedure when a new transmission is performed:

- The UE shall allocate resources to the logical channels in the following steps:
  - Step 1: All the logical channels with Bj > 0 are allocated resources in a decreasing priority order. If the PBR of a radio bearer is set to "infinity", the UE shall allocate resources for all the data that is available for transmission on the radio bearer before meeting the PBR of the lower priority radio bearer(s):
  - Step 2: the UE shall decrement Bj by the total size of MAC SDUs served to logical channel j in Step 1

NOTE: The value of Bj can be negative.

  - Step 3: if any resources remain, all the logical channels are served in a strict decreasing priority order (regardless of the value of Bj) until either the data for that logical channel or the UL grant is exhausted, whichever comes first. Logical channels configured with equal priority should be served equally.

Der Parameter B_j, der jedem der logischen Kanäle j zugeordnet und in der vorstehenden Einblendung erläutert ist, wird in jedem Übertragungszeitintervall (*Transmission Time Interval TTI*) für den betreffenden Kanal nach der Formel PBR x TTI erhöht und nach der Datenübertragung nach Schritt 1 in einem zweiten Schritt um die Gesamtgröße der nach obigem Schritt 1 zur Übertragung gelangten Daten aus dem betreffenden Kanal j verringert, wobei der Parameter B_j als Höchstwert höchstens die Übertragungsgrößeneinheit (bucket size) des betreffenden logischen Kanals j annehmen kann. Die Erhöhung wird dabei auch dann durchgeführt, wenn in dem logischen Kanal j keine Daten zur Übertragung anstehen.

Die Klägerin wendet sich mit ihrer Klage gegen sämtliche von der Beklagten in der Bundesrepublik vertriebenen LTE-fähigen Mobiltelefone der X-Gruppe, insbesondere die Modelle 1, 2, 3 und 4 (im Folgenden „angegriffene Ausführungsformen").

Die Klägerin wies die französische X SAS vor Klageerhebung schriftlich am 13. Oktober 2014 (Anlage K 4a) unter Beifügung einer Liste der betroffenen Patente darauf hin, dass sie durch den Vertrieb ihrer Mobiltelefone UMTS- und LTE-standardessentielle Patente der Klägerin verletze. Die Klägerin bot der X SAS in der Folgezeit mehrere Treffen an, die indes nicht zustande kamen. In einem Telefonat Ende 2014 informierte die X SAS die Klägerin, dass ein

Treffen im Dezember 2014 nicht möglich sei. In einer E-Mail vom 12.01.2015 (Anlage K 4e) teilte die X SAS mit, dass von der Klägerin vorgeschlagene Termine für ein Treffen im Januar aufgrund des Aufenthalts ihrer Direktion im Ausland nicht wahrgenommen werden könnten. Auf weitere Terminsvorschläge der Klägerin für den Zeitraum Ende Februar bis Mitte März 2015 mit E-Mail vom 12.02.2015 (Anlage 4 f) reagierte die X SAS nicht. Mit Schreiben vom 28. Juli 2015 (Anlage K 4g) unterbreitete die Klägerin der X SAS ein Lizenzvertragsangebot (Anlage K 4g, Anhang 4) unter Beifügung einer Liste der patentverletzenden Produkte und standardessentiellen Patente (Anlage K 4g, Anhang 1 und 2) nebst technischen Beschreibungen (Anlage K 4g, Anhang 3, vgl. für das Klagepatent dort No. 13 unter den für den LTE-Standard aufgeführten Patenten). Weitere technische Erläuterungen zu den UMTS- und LTE-Patenten übersendete die Klägerin mit E-Mail vom 25. September 2015 (Anlage AR 9 mit Anhängen in Anlagen K 4h und K 4i, vgl. betreffend das Klagepatent Anlage K 4i, dort unter No. 13). Es kam in der Folgezeit aber nicht zum Abschluss eines Lizenzvertrages zwischen den Parteien, weshalb die Klägerin durch Klageschrift vom 16. Oktober 2015, bei Gericht eingegangen am 19. Oktober 2015, Klage erhob. Mit Schreiben datierend ebenfalls vom 16. Oktober 2015 (AR 10), das am 20. Oktober 2015 an die Klägerin übersandt wurde, teilte die X SAS der Klägerin, dass sie stets willens sei, nach Treu und Glauben die Bedingungen einer Lizenz an werthaltigen Patente zu verhandeln. Am 19. Oktober 2015 war der X SAS eine französische Klageschrift der Klägerin betreffend nicht standard-essentielle Patente von deren französischen Prozessbevollmächtigten übermittelt worden. Die Beklagte, die vor der Klageerhebung von der Klägerin nicht direkt kontaktiert worden war, erklärte nach Klageerhebung ein Interesse an einer Lizenznahme und unterbreitete der Klägerin einen Lizenzvertrag, der als Lizenzgebiet Deutschland, Österreich und die Schweiz sowie einen Lizenzsatz von 0,042% (*Compliance Rate*) bzw. 0,066 % (*Standard Rate*) des Nettoverkaufspreises je Einheit vorsah, wobei die Benutzungshandlungen in der Vergangenheit mit einem reduzierten Lizenzsatz von 0,0315 % vergütet werden sollten (vgl. Anlage AR 7). Mit Schreiben vom 25. August 2016 bot die X SAS der Klägerin unter Vorlage eines Lizenzvertrags (Anlagen AR 16 und 17) mit Blick auf den anstehenden Erwerb der Alleingesellschafterstellung ihrer Eigentümerin an der Beklagten an, zu im Wesentlichen gleichen Bedingungen, insbesondere zu den gleichen Lizenzsätzen, Lizenz am weltweiten LTE-/UMTS-Patentportfolio zu nehmen. Im selben Schreiben teilte die X SAS auch Umsatzzahlen mit (Anlage AR 18). Sie hinterlegte bei der Landesjustizkasse Bamberg Ende August 2016 einen Betrag von € 500.000,00 (vgl. Hinterlegungsschein, Anlage AR 20), wobei dieser Betrag die Lizenzzahlungen für die weltweiten Verkäufe von LTE-/UMTS-fähigen Geräten im Zeitraum 2013 bis 31. Juli 2016 mit Ausnahme von Deutschland, der Schweiz und Österreich, kalkuliert auf der Grundlage des in der Anlage AR 17 angebotenen Lizenzsatzes, in Höhe von EUR 257.000,00 zzgl. eines Sicherheitszuschlags abdecken soll. Die Beklagte selbst hatte zuvor ebenfalls Auskunft zu ihren Verkaufszahlen erteilt und ihrerseits auf dieser Grundlage EUR 90.000,00 hinterlegt.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten der Lizenzvertragsverhandlungen wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen.

nicht verwirklicht. Merkmal f fordere zum einen die aktive Anpassung eines ersten und zweiten Teils der Datengruppe durch eine vorherige Festlegung der Größe der jeweiligen Teilbereiche durch die Mobilstation mit einer anschließenden Befüllung der beiden Bereiche anhand der ersten und der zweiten Regel gem. Merkmalsgruppe d. Dies sei beim Standard nicht der Fall. Schritt 3 komme dort nur zur Anwendung, wenn noch Kapazitäten vorhanden seien. Selbst dann würden aber keine Bereich aktiv festgelegt, sondern eine Aufteilung würde sich rein passiv durch das Befüllung ergeben, was für eine Verwirklichung von Merkmal f nicht ausreiche. Zum anderen liege überdies keine Anpassung gemäß der durch Daten in jedem Warteschlangenspeicher relativ zu einem Verzögerungskriterium für den jeweiligen Warteschlangenspeicher erfahrenen Verzögerung im Sinne des Merkmal f vor. Der Parameter B_j stelle weder einen Indikator für eine anspruchsgemäße zeitliche Verzögerung der Daten noch ein anspruchsgemäßes Verzögerungskriterium dar. Es handle sich um eine bloße Datenmenge. Ungeachtet dessen könne er bereits deshalb keine Anhaltspunkte für eine zeitliche Verzögerung von Datenpaketen liefern, weil er auch dann größer Null sein könne, wenn überhaupt keine verzögerten Daten vorlägen. Für die Größe des ersten Teilbereichs des Transportblocks sei nicht die Verzögerung von Datenpaketen, sondern die Anzahl der Datenpakete in den Warteschlangenspeichern mit einem B_j-Wert größer Null relevant, so dass weder die Größe des ersten noch des zweiten Teils verzögerungsorientiert angepasst werde. Eine verzögerungsorientierte Zuteilung im Schritt 3 finde nicht statt, die Zuteilung erfolge strikt nach Priorität. Erst Recht finde keine Anpassung der beiden Teile des Transportblocks anhand der zeitlichen Verzögerung eines jeden Warteschlangenspeichers statt. Wenn die Größe des ersten und zweiten Teils von der PBR abhänge, wie die Klägerin behaupte, erfolge deren Anpassung auch deshalb nicht anhand einer zeitliche Verzögerung, sondern anhand eines Parameters, der von den höheren Schichten vorgegeben werde. Die Klägerin habe die Verwirklichung des Merkmals f letztlich nicht schlüssig dargelegt. Überdies fehle es an schlüssigem Vortrag der Klägerin zur Verwirklichung des Merkmals c durch den Standard. Das Vorhandensein eines patentgemäßen Warteschlangenspeichers im Sinne des Merkmals c für jeden logischen Kanal werde mit Nichtwissen bestritten. Logische Kanäle könnten sich auch einen physikalischen Speicher teilen.

Im Übrigen stehe der Durchsetzung der Unterlassungs-, Rückruf- und Vernichtungsansprüche der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand entgegen. Die Klägerin habe insbesondere vor Klageerhebung nie erläutert, weshalb die von ihr geforderte Stücklizenz FRAND-Bedingungen entspreche. Die Lizenzbereitschaftserklärung der X SAS mit Schreiben vom 16.10.2015 sei nicht verspätet erfolgt, da der X SAS eine ausreichende Zeitspanne zur Prüfung der überlassenen Unterlagen zuzugestehen sei. Maßnahmen gegenüber der X SAS seien der Beklagten überdies ohnehin nicht zuzurechnen. Die Beklagte sei bis zur Veränderung ihres Gesellschafterbestands vor dem 29.08.2016 von keiner anderen X-Gesellschaft beherrscht worden, da verschiedene Geschäftsgegenstände, darunter auch der Abschluss eines Lizenzvertrags, nach ihrem Gesellschaftsvertrag Einstimmigkeit bedurft hätten.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Vortrags der Parteien wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

Das hiesige Verfahren ist durch Abtrennung (vgl. Beschluss vom 16.02.2016, AS 158) aus dem Ursprungsverfahren 7 O 212/15 hervorgegangen, das vier Patente umfasste. Das hiesige Klagepatent ist das Klagepatent 4 des Ursprungsverfahrens, dortige Antragsgruppe C.

Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage ist nur im aus dem Tenor ersichtlichen Umfang begründet.

Die angegriffenen Ausführungsformen machen von Anspruch 7 unmittelbar wortsinngemäßen Gebrauch. Die Klägerin ist auch nicht aus kartellrechtlichen Gründen gehindert, insbesondere ihre auf Unterlassung, Vernichtung und Rückruf/Entfernung aus den Vertriebswegen gerichteten Ansprüche durchzusetzen.

I.

Das Klagepatent betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung für das Zusammenstellen von Datenpaketen, etwa in Mobilfunknetzwerken.

Zum Hintergrund erläutert das Klagepatent, dass in Kommunikationssystemen Datenpakete mit unterschiedlichen Prioritäten zusammengestellt werden müssten, wofür der Begriff „multiplexen" verwendet wird. Anhand des Beispiels des aus verschiedenen Protokollschichten zusammengesetzten UMTS-Standards erläutert das Klagepatent, dass dort an der MAC-Schicht (Medium Access Control) Datenpakete, nämlich MAC-d Protokolldaten (Protocol Data Units = PDUs), für die Übertragung zu verbesserten (enhanced) MAC-e PDUs zusammengefasst würden. Dabei würden die Datenpakete nach der ihnen zugewiesenen Priorität zusammengestellt. Bei einer begrenzten Kapazität der für die Übertragung zusammengestellten Datengruppe, der Mac-e PDUs, könne eine reine Zusammenstellung nach der Priorität dazu führen, dass Datenpakete mit einer geringeren Priorität nicht zum Zuge kommen und „verhungern." Eine ausschließliche Orientierung an der Priorität würde nicht immer zu einer optimalen Befüllung der MAC-e PDUs führen und sei zu unflexibel, um alle „Quality of Service"-Anforderungen für PDUs, wie Anforderungen an die Verzögerung und die Übertragungsraten dieser Daten, zu erfüllen. Als im Stand der Technik bekannte Lösungsmöglichkeit erwähnt das Klagepatent die US-Anmeldung No. 2004/0042420, bei der der Multiplexer, also die Einheit, die die Zusammenstellung der Daten für die Übertragung vornehme, segmentierte Datenpakete mit niedriger Priorität jeweils nach einer Übertragung von n Datenpaketen mit einer hohen Priorität übertrage.

Vor diesem Hintergrund stellt sich das Klagepatent die Aufgabe, ein flexibles und effizientes Multiplexen von Datenpaketen zu ermöglichen. Soweit es eine Vorrichtung betrifft, schlägt das Klagepatent eine Vorrichtung nach Anspruch 7 vor, der sich wie folgt übersetzen und gliedern lässt:

a Multiplexgerät (300) zum Multiplexen von Datenpaketen mit verschiedenen zugeordneten Prioritäten, mit:

b Mitteln (10) zum Empfangen von Datenpaketen;

c Mitteln (30, 40) zum Bedienen eines Warteschlangespeichers (50) für jede unterschiedliche Priorität von Datenpaketen;

d Mitteln (60, 80) zum Zusammensetzen einer Gruppe der Datenpakete, wobei

d1 durch Auswählen von Datenpaketen aus einem oder mehreren der Warteschlangespeicher (50) nach einer ersten Regel ein erster Teil (90) der Gruppe mit Datenpaketen befüllt wird und

d2 durch Auswählen von Datenpaketen aus einem oder mehreren der Warteschlangespeicher (50) nach einer zweiten Regel ein zweiter Teil (95) der Gruppe mit Datenpaketen befüllt wird;

e Mitteln (100) zum Übertragen der Gruppe;

gekennzeichnet durch,

f Mittel (110) zum Anpassen der Größe des ersten und zweiten Teils (90,95) gemäß der durch Daten in jedem Warteschlangenspeicher (50) relativ zu einem Verzögerungskriterium für den jeweiligen Warteschlangenspeicher (50) erfahrenen Verzögerung.

II.

Die angegriffenen Ausführungsformen machen von Anspruch 7 des Klagepatents wortsinngemäß Gebrauch. Dies steht aufgrund zutreffender patentrechtlicher Bewertung der Parteien für sämtliche Anspruchsmerkmale mit Ausnahme der Merkmalsgruppe d und der Merkmale c und f außer Streit. Die angegriffenen Ausführungsformen verwirklichen jedoch auch die streitigen Merkmale.

Maßgeblich für die Auslegung eines Patents ist zunächst der Inhalt und damit der Wortlaut und Sinngehalt des jeweiligen Patentanspruchs, Beschreibung und Zeichnungen sind ergänzend heranzuziehen (Art. 69 Abs. 1, S. 1, 2 EPÜ). Soweit die Beschreibung zur Auslegung der Patentschrift herangezogen wird, ist der technische Sinn der in der Patentschrift verwendeten Worte und Begriffe entscheidend und nicht deren rein philologischer oder logisch-wissenschaftlicher Bedeutungsgehalt (BGHZ 150, 149, 156 – *Schneidmesser I* BGH GRUR 1999, 909 – *Spannschraube*). Die Merkmale eines Patentanspruchs müssen deshalb aus der Patentschrift, die insoweit ihr eigenes Lexikon darstellt, selbst heraus ausgelegt werden (BGH, GRUR 2005, 754 – *werkstoffeinstückig*). Ausführungsbeispiele sowie darauf bezogene Beschreibungsteile schränken einen weiter zu verstehenden Sinngehalt des Patentanspruchs nicht auf diese Ausführungsformen ein.

Bei Zugrundelegen dieser Maßstäbe sind die streitigen Merkmale durch die angegriffenen Ausführungsformen unmittelbar wortsinngemäß verwirklicht.

1. Merkmal c sieht Mittel zum Bedienen eines Warteschlangenspeichers für jede unterschiedliche Priorität von Datenpaketen vor. Soweit die Beklagte mit Blick auf die Existenz von Warteschlangenspeichern *(queue store)* den Vortrag der Klägerin für unschlüssig hält und deren Existenz mit Nichtwissen bestreitet, dringt sie damit nicht durch.

   a) Zunächst ist festzustellen, dass Merkmal c lediglich Mittel zum Bedienen eines anspruchsgemäßen Speichers vorsieht, mithin der Speicher selbst nicht Teil des Multiplexgeräts sein muss. Aus dem Begriff des Warteschlangenspeichers bzw. *queue storage* folgt, dass dieser in der Lage sein muss, Daten in einer bestimmten Reihenfolge zu speichern. Nimmt man den technisch-funktionalen Zusammenhang in den Blick, nämlich dass es darum geht, eine zu übersendende Datengruppe gerade auch in Szenarien zusammenzustellen, in denen die Kapazität der Datengruppe nicht ausreicht, um sämtliche Datenpakete zu übertragen, so dass eine Auswahl getroffen werden muss, ergibt sich als weitere Anforderung an einen *queue storage*, dass er auch Daten einer bestimmten Priorität, die bei einer Übertragung nicht zum Zug gekommen sind, als zu dieser Priorität gehörend speichern kann, bis diese für die Übertragung ausgewählt werden. Weitere Vorgaben für die Ausgestaltung des Warteschlangenspeichers, der von einem merkmalsgemäßen Mittel bedient werden können muss, mit Ausnahme des Umstands, dass ein solcher Speicher für jede unterschiedliche Priorität von Datenpaketen vorhanden sein muss, sieht der Patentanspruch nicht vor. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus dem übrigen Inhalt der Patentschrift, der für die Auslegung des Anspruchs heranzuziehen ist. Demnach legt sich das Klagepatent nicht darauf fest, ob der eine Warteschlangenspeicher für jede unterschiedliche Priorität von Datenpaketen durch physisch getrennte Speicher realisiert ist. Es genügt vielmehr etwa auch ein einheitlicher physischer Speicher, in dem jeder Prioritätsklasse unterschiedliche virtuelle Speicherbereiche zugewiesen sind, sei es etwa durch Reservierung von bestimmten Zonen auf dem physischem Speicher oder durch bestimmte Ablegeregeln, die bewirken, dass zusammengehörige Datenpakete nach diesen Regeln an bestimmten Speicheradressen, die für eine bestimmte Prioritätsklasse auch nicht physisch benachbart sein müssen, abgelegt und von dort durch Anwendung dieser Regeln wieder abgerufen werden können. Dieser Befund wird auch durch das technisch-funktionale Verständnis gestützt. Für die Lehre des Klagepatents ist nämlich unerheblich, wie das Konzept eines Warteschlangenspeichers technisch realsisiert wird, solange Daten einer Prioritätsklasse abgespeichert und wieder abgerufen werden können. Dann ist es nämlich möglich, für Datenpakete mit unterschiedlicher Priorität zwei unterschiedliche Regeln für das Befüllen der zu übertragenden Datengruppe anzuwenden.

   Übertragen auf das anspruchsgemäße Mittel, das allein merkmalsgegenständlich ist und einen Warteschlangenspeicher bedienen können muss, bedeutet dies, dass das Mittel mit je einem Warteschlangenspeicher für jede unterschiedliche Priorität umgehen können muss, insbesondere Daten aus einem solchen Speicher als zu einer

bestimmten Prioritätsklasse gehörend erkennen und wie im Anspruch vorgesehen mit ihnen arbeiten können muss.

b) Dass der Standard voraussetzt, dass die Daten der jeweiligen Prioritätsklasse bzw. des jeweiligen logischen Kanals so abgespeichert sind, dass sie als zusammengehörige Daten einer Prioritätsklasse identifiziert und übertragen bzw. – falls sie nicht am Zug sind – für die spätere Übertragung abrufbar vorgehalten werden können, ergibt sich eindeutig aus den Schritten in Abschnitt 5.4.3.1 des Standards. Nur wenn die Daten eines logischen Kanals als zusammengehörig gespeichert sind, kann ihnen der Parameter B_i zugeordnet werden. Nur wenn sie im Zugriffsbereich des Multiplexgeräts gespeichert sind, kann dieser entscheiden, ob die Daten je nach ihrer Zuordnung sofort übersendet werden oder ihre Übertragung auf einen späteren Zeitpunkt zurückgestellt wird. Vor diesem Hintergrund war es für die Schlüssigkeit der Klage nicht erforderlich, dass die Klägerin im Einzelnen dazu vorträgt, wie die Daten bei den angegriffenen Ausführungsformen abgespeichert werden. Da mithin klar ist, dass die Daten so abgespeichert werden, dass sie als einem bestimmten logischen Kanal zugehörig wieder aufgerufen werden können, wenn sie nach den Übertragungsregeln zur Übertragung anstehen, geht auch das bloße Bestreiten der Beklagten mit Nichtwissen ins Leere. Es ist überdies auch unzulässig, da die Beklagte nicht darlegt, wieso sie als Unternehmen der X-Gruppe nicht in der Lage sein soll dazu vorzutragen, wie die Daten – so es denn, wie nicht, darauf ankommen sollte – bei den für die X-Gruppe hergestellten angegriffenen Ausführungsformen abgespeichert werden.

2. Entgegen der Auffassung der Beklagten sind auch die Merkmale der Merkmalsgruppe d verwirklicht. Merkmalsgruppe d sieht Mittel (60, 80) zum Zusammensetzen einer Gruppe der Datenpakete vor, wobei (Untermerkmal d 1) durch Auswählen von Datenpaketen aus einem oder mehreren der Warteschlangespeicher (50) nach einer ersten Regel ein erster Teil (90) der Gruppe mit Datenpaketen befüllt wird und (Untermerkmal d 2) durch Auswählen von Datenpaketen aus einem oder mehreren der Warteschlangespeicher (50) nach einer zweiten Regel ein zweiter Teil (95) der Gruppe mit Datenpaketen befüllt wird.

a) Mit der Zweckbestimmung „Mittel zum" legt die Merkmalsgruppe d bestimmte Fähigkeiten fest, die ein patentgemäßes Multiplexgerät haben muss. Demnach muss es dazu in der Lage sein, eine Gruppe der Datenpakete zusammenzusetzen. Dabei muss das Zusammensetzen so möglich sein, dass durch Auswählen von Datenpaketen aus einem oder mehreren Warteschlangenspeicher nach einer ersten Regel ein erster Teil der Gruppe mit Datenpaketen befüllt und durch Auswählen von Datenpaketen aus einem oder mehreren Warteschlangenspeicher nach einer zweiten Regel ein zweiter Teil der Gruppe mit Datenpaketen befüllt wird. Hieraus folgt, dass ein patentgemäßer Multiplexer nach zwei unterschiedlichen Regeln befüllen können muss. Ob er daneben auch noch dazu in der Lage ist, nach einer weiteren Regel zu befüllen, hierzu enthält das Klagepatent keine Festlegung und schließt dies insbesondere auch

nicht aus. Soweit der Anspruch eine Datengruppe erwähnt, handelt es sich nicht um einen irgendwie gearteten physischen Bestandteil des Multiplexgeräts wie etwa einen besonderen physikalischen Speicher, denn das Multiplexgerät muss nur Mittel zum Zusammensetzen einer Datengruppe im Sinne der Merkmalsgruppe d enthalten. Der Anspruch spricht auch nur allgemein von Datengruppe, ohne auf die Art und Weise der technischen Realisierung einzugehen. Die Datengruppe stellt daher lediglich eine Menge von Daten dar, ohne dass das Klagepatent eine bestimmte Form der physischen Abspeicherung vorschreiben würde. Dementsprechend sind auch der erste und der zweite Teil einer Datengruppe nicht so zu verstehen, dass sich die Merkmalsgruppe d etwa auf einen bestimmten physikalischen Speicher, der in zwei Teile geteilt ist, bezieht. Auch insofern handelt es sich lediglich um abstrakte Teilmengen der Datengruppe. Dabei ist nicht erforderlich, dass eine Datengruppe stets aus zwei nicht leeren Teilmengen bestehen muss, die nach zwei unterschiedlichen Regeln befüllt werden, mithin stets zwei Regeln zur Anwendung kommen müssten. Der Patentanspruch legt schon nicht fest, dass eine Datengruppe stets und ausnahmslos aus zwei solchen Teilen bestehen müsste. Abgesehen davon fordert Merkmalsgruppe d lediglich eine bestimmte Eignung des Multiplexgerätes, nämlich Datenpakete nach der Merkmalsgruppe d zusammenstellen zu können. Nicht gefordert ist darüber hinaus, dass der Multiplexer diese Eignung stets nutzen müsste, indem er stets und ausschließlich zwei Regeln anwendet und damit zweigeteilte Datengruppen zusammenstellt, in denen sowohl nach der ersten als auch nach der zweiten Regel ausgewählte Datenpakete enthalten sind. Es genügt, dass er solche Datengruppen zusammenstellen kann. Die Regeln, die der Multiplexer bei der Auswahlentscheidung anwenden können muss, müssen demnach nicht so ausgestaltet sein, dass sie stets zu einer Befüllung der Datengruppe mit sowohl nach der ersten als auch nach der zweiten Regel ausgewählten Daten führen.

Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus Abschnitt [0008] der Patentbeschreibung. Es spricht schon vieles dafür, dass sich diese Ausführungen allein auf den Verfahrensanspruch 1 beziehen, denn in Abschnitt [0007] wird einleitend der Verfahrensanspruch als ein Aspekt der Erfindung genannt, während erst im Anschluss an die nachfolgenden Abschnitte, nämlich in Abschnitt [0013], der Vorrichtungsanspruch als ein zweiter Aspekt der Erfindung genannt wird. Aber selbst wenn man Abschnitt [0008] als allgemeine Beschreibung der erfindungsgemäßen Vorrichtung ansehen wollte, könnte hieraus nicht gefolgert werden, dass nur eine Eignung, stets und ausschließlich zweigeteilte Datenpakete unter ausnahmsloser Anwendung von zwei Regeln zusammenzustellen, patentgemäß wäre. Zwar heißt es dort, dass die Erfindung Flexibilität für eine angemessene Handhabung von Prioritäten, garantierten Bitraten und „Verhungern von Daten"-Szenarien dadurch bereitstelle, dass ein Datenpaket, das groß genug für die Unterbringung mehrere kleiner Datenpakete sei, in zumindest zwei Teile geteilt wird und dass ermöglicht wird, unterschiedliche

Multiplex-Regeln für verschiedene Teile zu benutzen. Gleichzeitig heißt es jedoch auch, dass auf diese Weise die Übersendung einer Kombination von Datenpaketen mit unterschiedlicher Priorität ermöglicht werden kann *(„may be transmitted")*. Hieraus ergibt sich, dass nicht jede zu übertragende Datengruppe in zwei Teile geteilt sein muss, sondern auch eine Datengruppe mit Daten nur einer Priorität zulässig ist. Hinzu kommt, dass es sich bei Anspruch 7 um einen Vorrichtungsanspruch handelt, der in Merkmalgruppe d – wie bereits ausgeführt – lediglich eine Eignung vorsieht, nicht aber ausschließt, dass die Vorrichtung auch nach anderen Vorgaben verfahren kann. Mithin genügt es für die Verwirklichung der Merkmalsgruppe d, wenn der Multiplexer dann, wenn zwei unterschiedliche Regeln zur Anwendung kommen sollen, dazu in der Lage ist, eine zu übertragende Datengruppe zu befüllen, indem für einen ersten Teil nach der ersten und für einen zweiten Teil nach der zweiten Regel ausgewählt wird.

Nichts anderes ergibt sich auch aus Abschnitt [0015] der Klagepatentschrift, in dem es heißt, dass der Ausgangsspeicher einen ersten und einen zweiten Teil umfasst und beide jeweils mindestens ein Datenpaket unterbringen können, zumal es sich um ein Ausführungsbeispiel handelt und Anspruch 7 abstrakt von einer Datengruppe spricht und sich nicht auf einen Speicher festlegt.

Ebenso wenig ist erforderlich, dass von vornherein eine bestimmte Größe für die Datengruppe und für ihren ersten und zweiten Teil festgelegt wird. Auch insoweit enthält der Patentanspruch keine Vorgaben. Hinzu kommt wiederum, dass Anspruch 7 lediglich eine bestimmte Eignung fordert, nämlich einen ersten Teil der Datengruppe nach einer ersten und einen zweiten Teil nach einer zweiten Regel zu befüllen, ohne dass vorgegeben würde, dass der Multiplexer immer so verfahren müsste.

Auch aus dem Umstand, dass das Klagepatent ein „Verhungern" von Datenpaketen zum Ausgangspunkt seiner Überlegungen gewählt hat, folgt nicht, dass der Multiplexer stets bei jedem Befüllen der zu übertragenden Datengruppe zwei Regeln anwenden müsste. Wiederum gilt, dass Merkmalsgruppe d lediglich fordert, dass er geeignet ist, zwei Regeln bei der Auswahl anzuwenden und damit einen ersten und zweiten Teil der Datengruppe zu befüllen. Dass ein Verhungern von Daten ausgeschlossen sein müsste, hat im Patentanspruch keinen Niederschlag gefunden.

Soweit in den Merkmalen d1 und d2 das Befüllen der Datengruppe mit Daten aus mindestens einem Warteschlangenspeicher nach einer ersten bzw. zweiten Regel angesprochen ist, bedeutet dies nicht, dass beide Regeln nur solche Daten beträfen, die bereits bei einer Übertragung nicht zum Zuge gekommen sind und daher auf ihre Übertragung „warten" würden. Mit Warteschlangenspeicher in den Merkmalen d1 und d2 wird lediglich die Fähigkeit der Speicher zum Ausdruck gebracht, dass diese Speicher auch dazu in der Lage sein müssen, nicht zum Zuge gekommene Datenpakete zu speichern, bis diese für die Übertragung an der Reihe sind. Irgendwelche Einschränkungen mit Blick auf den Inhalt der beiden Regeln, etwa dass

es sich um Regeln handeln müsste, die jeweils nur verzögerte Daten betreffen, sind damit nicht verbunden. Eine solche Einschränkung widerspräche auch Unteranspruch 8, der gerade vorsieht, dass nach der ersten Regel nur Datenpakete mit der höchsten Priorität ausgewählt werden. Das Klagepatent schließt es mithin nicht aus, dass ein Teil der übertragenen Datenpakete solche sind, die nicht verzögert sind.

b) Vor diesem Hintergrund verwirklichen die angegriffenen Ausführungsformen die Merkmalsgruppe d, weil sie ein Befüllen mit zwei unterschiedlichen Regeln durchführen können.

Nach Abschnitt 5.4.3.1 des Standards übermittelt der RRC für jeden logischen Kanal eine Priorität *(Priority)*, wobei ein ansteigender Wert ein geringeres Prioritätslevel anzeigt, eine *prioritizedBitRate*, die eine priorisierte Bitrate (PBR) festlegt, und eine *bucketSizeDuration*, die die Dauer der Größe der Übertragungseinheit (BSD) festlegt. Ferner erhält die Mobilstation für jeden logischen Kanal j einen Parameter B_j, der bei der Einrichtung des logischen Kanals mit dem Wert Null initialisiert wird und wie im Tatbestand dargestellt berechnet wird. Anknüpfend an diesen Parameter sieht das Verfahren in Abschnitt 5.4.3.1 des Standards bei der Zuteilung der Übertragungskapazitäten des Transportblocks an die einzelnen logischen Kanäle bei einer neuen Übertragung vor, dass zunächst alle logischen Kanäle mit $B_j > 0$ in absteigender Prioritätsreihenfolge zum Zuge kommen. Erst wenn danach noch Platz in dem zu übersenden Transportblock ist, kommen im Zuge des dritten Schritts die übrigen logischen Kanäle in streng absteigender Prioritätsreihenfolge zum Zuge.

Damit sieht der Standard anhand des Unterscheidungskriteriums $B_j > 0$ zwei verschiedene Regeln für das Befüllen des Transportblocks mit Daten der logischen Kanäle vor. Der Schritt 1 stellt die erste Regel dar, nach der ein erster Teil der zu übertragenden Datengruppe befüllt wird, nämlich mit Daten aus logischen Kanälen mit $B_j > 0$. Der Schritt 3 ist die zweite Regel, nach der allein nach Priorität ein zweiter Teil befüllt wird. Damit sorgt dieses Verfahren dafür, dass nicht allein hochpriorisierte Daten übersandt werden, indem solche Daten mit niedriger Priorität, die indes einen positiven B_j haben, weil sie beim letzten Übertragungsvorgang nicht berücksichtigt wurden, nun vorrangig vor den Daten des logischen Kanals mit der höchsten Priorität, der jedoch beim letzten Übertragungsvorgang berücksichtigt wurde, übersandt werden.

Nach der oben dargelegten Auslegung des Patentanspruchs ist es unerheblich, dass es möglich ist, dass durch ein Setzen der PBR auf Unendlich für einen logischen Kanal mit einer zur Übertragung anstehenden Menge an Daten, die die Kapazität der zu übertragenden Datengruppe übersteigt, bewirkt wird, dass nur diese höchstpriorisierten Daten in die Datengruppe gelangen, und dass durch unbegrenztes Wiederholen dieser Einstellung sogar gänzlich verhindert werden kann, dass andere Daten mit niedriger Priorität übertragen werden, denn es genügt, dass nach dem Standard auch Fälle möglich sind, in denen beide Auswahlschritte zur Anwendung kommen und die LTE-

fähigen Mobilstationen dann auch diese Auswahl umsetzen können. Wie ausgeführt fordert das Klagepatent nicht, dass die Datengruppe stets und ausschließlich nach zwei unterschiedlichen Regeln zusammengesetzt wird. Aus dem gleichen Grund ist es unschädlich, dass es auf der Grundlage des Standards denkbar ist, dass so viele Daten in einem oder mehreren logischen Kanälen mit $B_i > 0$ zur Übertragung anstehen, dass in der Datengruppe kein Platz mehr für die Datenpakete nach Schritt 3 des Standardabschnitts 5.4.3.1 ist und daher alle zu übersendenden Datenpakete nach nur einer Regel zusammengestellt sind. Patentrechtlich ohne Bedeutung ist auch, ob mit den Auswahlregeln des Standards sicher verhindert wird, dass einige Datenpakete „verhungern". Denn dass ein solches Verhungern unter allen Umständen ausgeschlossen sein müsste, hat jedenfalls keinen Niederschlag im Patentanspruch gefunden.

3. Auch Merkmal f des Klagepatents ist durch die nach dem LTE-Standard arbeitenden angegriffenen Ausführungsformen verwirklicht. Merkmal f sieht Mittel (110) zum Anpassen der Größe des ersten und zweiten Teils (90,95) [erg: der zu übertragenden Datengruppe] gemäß der durch Daten in jedem Warteschlangenspeicher (50) relativ zu einem Verzögerungskriterium für den jeweiligen Warteschlangenspeicher (50) erfahrenen Verzögerung vor.

   a) Merkmal f sieht zunächst ein Verzögerungskriterium für den betreffende Warteschlangenspeicher vor. Ein merkmalsgemäßes Verzögerungskriterium muss sich demnach auf den Warteschlangenspeicher, der wiederum Datenpakete mit gleicher Priorität enthält, und nicht auf die Daten selbst beziehen. Welchen weiteren konkreten Inhalt das Verzögerungskriterium hat, insbesondere auf welche Weise es eine Verzögerung zum Ausdruck bringt, lässt das Merkmal offen. Insbesondere sind anspruchgemäße Verzögerungskriterien nicht allein solche Größen, die die Dimension bzw. Maßeinheit Zeit haben. Eine entsprechende Einschränkung lässt sich dem maßgeblichen Wortlaut des Patentanspruchs nicht entnehmen. Zwar wird in Abschnitt [0012] der Patentbeschreibung eine Anpassung gemäß einer durch die Daten erfahrenen Verzögerung in der Warteschlange relativ zu einem Verzögerungskriterium u.a. einer Anpassung gemäß der Datenmenge in den Warteschlangenspeichern gegenübergestellt. Hieraus lässt sich jedoch nicht mit der notwendigen Sicherheit entnehmen, dass die Patentbeschreibung eine Datenmenge nicht als Verzögerungskriterium auffassen würde. Denn auch die Feststellung der Existenz einer Verzögerung durch das Vorhandensein einer verzögerten Datenmenge kann als Verzögerungskriterium angesprochen werden.

   Ferner stellt Merkmal f auf eine Verzögerung *(delay)* ab, die die Daten in jedem Warteschlangenspeicher relativ zu dem Verzögerungskriterium erfahren haben. Mit einer Verzögerung der Daten ist gemeint, dass die betreffenden Daten bei einer Übersendung nicht zum Zuge gekommen sind. Auch insoweit lässt der Anspruch offen,

wie im Einzelnen technisch festgestellt wird, dass eine Verzögerung bei den Daten vorliegt, solange die Verzögerung relativ zu einem Verzögerungskriterium für den Warteschlangenspeicher der betroffenen Daten ist. Gemäß dieser Verzögerung der Daten wird die Größe des in Merkmalsgruppe d genannten ersten und zweiten Teils der zu übertragenden Datengruppe angepasst. Eine Anpassung in diesem Sinne ist nicht nur dann gegeben, wenn eine bereits von vornherein vorgegebene Größe aktiv angepasst wird, sondern auch dann, wenn infolge einer Verzögerung Regeln zur Anwendung kommen, die sich auf die Größe des ersten und zweiten Teils der Datengruppe auswirken. Dem Wortlaut lässt sich das Erfordernis einer aktiven Anpassung einer vorher vorgegebenen Größe nicht entnehmen. Vielmehr sieht der Vorrichtungsanspruch 7 allein vor, dass Mittel vorhanden sein müssen, die eine entsprechende Anpassung bewirken. Auf welche Weise dies geschieht, lässt der Anspruch offen. Insbesondere können daher auch die zur Anwendung berufenen Auswahlregeln Mittel sein, die zu einer Anpassung der Größe führen. Die Beklagte hat auch keine Stelle in der Patentbeschreibung aufgezeigt, die ein anderes Verständnis rechtfertigen würde. Dem Klagepatent lässt sich ferner nicht entnehmen, dass der Umfang der Verzögerung in den Warteschlangenspeichern die Art und Weise der Aufteilung, insbesondere die Größe des ersten und zweiten Teils beeinflussen müsste. Es genügt vielmehr, wenn lediglich daran angeknüpft wird, dass eine Verzögerung vorliegt, und dieser Umstand die Aufteilung beeinflusst.

Da auch Merkmal f lediglich Mittel vorsieht, die in der Lage sind, wie in Merkmal f vorgesehen zu verfahren, aber nach seinem Wortlaut nicht ausschließt, dass das Multiplexgerät auch auf andere Weise verfahren kann, oder vorgibt, dass das Multiplexgerät immer wie in Merkmal f niedergelegt verfahren müsste, führt es aus dem Anspruch nicht heraus, wenn ein Multiplexgerät nicht immer die Prozedur nach Merkmal f durchführt, sondern etwa Daten auch unabhängig von einer Verzögerung priorisiert, etwa weil aus dem betreffenden Warteschlangenspeicher bei der letzten Übersendung keine Daten mangels anstehender Daten übersendet wurden.

b) Nach der vorstehenden Maßgabe machen die angegriffenen Ausführungsformen von Merkmal f Gebrauch.

Der Parameter B_j stellt ein merkmalsgemäßes Verzögerungskriterium dar. Wie ausgeführt muss sich ein solches Verzögerungskriterium auf den betreffenden Warteschlangenspeicher beziehen. Dies ist bei dem Parameter B_j nach dem Standard der Fall. Nach Abschnitt 5.4.3.1 ist dieser Parameter dem jeweiligen logischen Kanal j zugeordnet, für den eine festgelegte Priorität besteht. Für jedes Übertragungsintervall wird der Parameter um den Faktor PBR x TTI erhöht und nach Schritt 1 um die Menge der nach Schritt 1 übertragenen Daten reduziert. Er ist damit ein Maß für eine Verzögerung des Kanals selbst und gibt an, ob der Kanal bei der letzten Versendung voll zum Zuge kam. Ein positiver Wert kann dabei verschiedene Ursachen haben. Zum

einen kann er theoretisch darauf beruhen, dass in einem Zeitintervall eine kleinere Datenmenge übertragen wurde, als das Produkt PBR x TTI, also die priorisierte Bitrate mal der Zeiteinheit, als Datenmenge angibt, sei es, weil in die zu übertragende Datengruppe weniger Daten dieses Kanals eingestellt wurden, als zur Übertragung anstehen, oder weil die in dem Kanal vorhandene Datenmenge kleiner als die Summe aus dem alten Wert für B_j und dem Produkt PBR x TTI ist. Überdies findet die Erhöhung um den Faktor PBR x TTI unabhängig davon statt, ob für diesen Kanal überhaupt Datenpakete zur Übertragung anstehen. Auch aus diesem Grund kann ein logischer Kanal einen Wert $B_j > 0$ aufweisen, obwohl für diesen Kanal keine verzögerten Datenpakete vorhanden sind, die im vorangegangenen Übertragungsintervall nicht zum Zuge gekommen sind. Ein positiver Wert von B_j für einen Kanal bringt daher zum Ausdruck, dass der Kanal – aus welchen Gründen auch immer – bei den letzten Übertragungsvorgängen nicht im Umfang des Produktes PBR x TTI zum Zuge kam und daher insoweit verzögert ist. Mithin handelt es sich bei dem Parameter B_j um ein Verzögerungskriterium für den Kanal. Es kann daher offen bleiben, ob eine Anknüpfung an eine Datenmenge aufgrund einer bewussten Auswahlentscheidung der Patentinhaberin nach den Grundsätzen der Entscheidung des Bundesgerichtshofs, GRUR 2011, 701 ff. – Okklusionsvorrichtung nicht patentgemäß wäre, da der Parameter B_j nicht, jedenfalls nicht unmittelbar an eine Datenmenge, sondern an eine Verzögerung des Kanals anknüpft. Aber selbst wenn man das Verzögerungskriterium als Verzögerungskriterium für die Daten selbst, das für den jeweiligen Kanal festgelegt ist, verstehen wollte, würde es aus dem Patentanspruch nicht hinausführen, dass B_j seiner Dimension nach eine Datenmenge darstellt. Wie dargelegt, muss das Verzögerungskriterium keine zeitliche Größe in dem Sinne sein, dass es die Dimension/Maßeinheit „Zeit" hat.

Sind indes Daten eines bestimmten logischen Kanals bei einer vorangegangenen Übersendung nicht zum Zug gekommen, handelt es sich um verzögerte Daten im Sinne des Klagepatents. In diesem Fall stellt der Parameter B_j mit einem positiven Wert zugleich einen Hinweis dar, dass diese Daten verzögert sind. Es handelt sich damit um Daten, die relativ zum Verzögerungskriterium für den betreffende Warteschlangenspeicher verzögert sind und die daher nach Schritt 1 behandelt werden. Dass nach dem Standard nach dem Vorstehenden ein Kanal mit $B_j > 0$ auch ohne verzögerte Daten existieren kann und dann nach Schritt 1 bevorzugt behandelt wird, mithin ein positiver Wert keine hinreichende Bedingung für die Existenz verzögerter Daten ist, führt nach den obigen Ausführungen nicht aus dem Patentanspruch hinaus, da dieser lediglich bestimmte Fähigkeiten fordert, aber nicht vorschreibt, dass das Multiplexgerät mit Datenpaketen ausschließlich wie in den Merkmalen d und f beschrieben verfährt.

Nicht von den Parteien erörtert wurde, ob es Konstellationen geben kann, in denen verzögerte Daten vorliegen und in denen B_j gleichwohl nicht positiv ist, weil er auch

negative Werte annehmen kann, so dass die Erhöhung um den Faktor PBR x TTI unter Umständen vielleicht keinen positiven Wert ergibt, obwohl verzögerte Daten vorliegen, so dass ein positiver Wert keine notwendige Bedingung für die Existenz verzögerter Daten sein könnte. Aus den im Rahmen der Auslegung erörterten Gründen kann dies jedoch dahinstehen. Denn wiederum gilt, dass der Patentanspruch nicht vorschreibt, dass die Vorrichtung ausschließlich nach der Merkmalsgruppe d verfährt.

Sind logische Kanäle mit verzögerten Datenpaketen, die bei der vorangegangenen Übertragung nicht zum Zug gekommen sind, vorhanden, haben diese nach dem Standard jedenfalls in bestimmten Konstellationen einen positiven Wert B_i und werden daher nach Schritt 1 behandelt. Damit haben vorhandene verzögerte Daten unmittelbaren Einfluss auf die Größe der Teilmenge des Transportblocks, die nach Schritt 1 behandelt wird. Dass es – wie erörtert – auch Konstellationen gibt, in denen $B_i > 0$ ist, obwohl keine verzögerten Daten vorhanden sind, oder B_i trotz verzögerter Daten evtl. sogar nicht positiv sein mag und damit die Größe des ersten Teils der zu übertragenden Datengruppe insoweit nicht, jedenfalls nicht allein durch die Verzögerung von Daten, bestimmt wird, ist unerheblich. Denn nach dem Standard sind auch Konstellationen möglich, in denen bei positiven B_i-Werten verzögerte Daten vorliegen. Auch in diesem Fall muss eine Mobilstation nach den Regeln in Abschnitt 5.4.3.1 arbeiten können, was wie dargelegt für die Verwirklichung des Merkmals f ausreicht. Der Patentanspruch verbietet es nicht, dass das Verzögerungskriterium in anderen Konstellationen kein Indikator für die Verzögerung von Daten ist. Wie ebenfalls bereits ausgeführt, fordert der Patentanspruch auch nicht, dass die Größe der Teile der zu übertragenden Datengruppe stets und ausschließlich nach dem Kriterium in Merkmal f bemessen wird. Für die Verwirklichung von Merkmal f reicht es vielmehr aus, wenn das Multiplexgerät eine Größenanpassung wie in Merkmal f vorgesehen bewirkt, sofern verzögerte Daten vorliegen.

Aus den gleichen Gründen ist es auch ohne Bedeutung, dass in bestimmten Konstellationen, etwa wenn die Anzahl der Daten in Kanälen mit positiven B_i-Werten die Kapazität der Datengruppe überschreitet, die Anpassung der Größe der beiden Teile nicht anhand der Verzögerung eines jeden Warteschlangenspeichers stattfindet, solange es Konstellationen gibt, in denen aufgrund der gewählten Parameter die positiven B_i-Werten mit der Existenz von verzögerten Daten gleichgesetzt werden können und die genannten zwei Regeln zur Anwendung kommen. Wie bereits ausgeführt, ist es auch nicht erforderlich, dass der Umfang der Verzögerung die Aufteilung beeinflusst.

Unerheblich für die Verwirklichung von Merkmal f ist ferner, dass in die Berechnung von B_i mit den Parametern PBR und TTI Werte einfließen, die von den höheren Schichten vorgegeben werden, und hierdurch das Vorzeichen von B_i mit bestimmt wird.

Dieser Umstand ändert nichts daran, dass der Parameter B_i jedenfalls in bestimmten Konstellationen ein Indikator für eine Verzögerung darstellt.

Aus den oben genannten Gründen ist es für die Verwirklichung von Merkmal f auch unschädlich, dass im Standard keine bestimmte Größe einer ersten und zweiten Teilmenge des Transportblocks vorgegeben und diese Größe dann vor jeder Übertragung aktiv anhand der Verzögerung nach Merkmal f angepasst wird. Es genügt vielmehr, dass die Anpassung Folge der für diesen Fall aufgerufenen Auswahlregeln ist.

Schließlich ist auch unerheblich, dass der Standard nicht auf Warteschlangenspeicher für jede unterschiedliche Priorität abstellt, sondern auf logische Kanäle abhebt, denen bestimmte Prioritäten zugewiesen sind. Denn die Daten aus einem logischen Kanal sind denklogisch abgespeichert und können als zusammengehörige Daten eines Kanals abgerufen werden, so dass die Speicherorte als patentgemäße Warteschlangenspeicher anzusehen sind.

III.

Nach alledem ist die Klage aufgrund der wortsinngemäßen Verletzung des Klagepatents durch die angegriffenen Ausführungsformen im aus dem Tenor ersichtlichen Umfang begründet.

1. Der Unterlassungsanspruch folgt im zugesprochenen Umfang aus § 139 Abs. 1 PatG i.V.m. Art. 64 EPÜ.

2. Die Schadensersatzverpflichtung ergibt sich aus § 139 Abs. 2 PatG i.V.m. Art. 64 EPÜ. Der Beklagten ist einen Monat nach Veröffentlichung des Hinweises auf die Patenterteilung jedenfalls ein Fahrlässigkeitsvorwurf hinsichtlich der Verletzung des Klagepatents zu machen. Da die Klägerin nicht in der Lage ist, den Schadensersatz zu berechnen, hat sie das für die Erhebung der Feststellungsklage notwendige Feststellungsinteresse.

3. Der Rechnungslegungsanspruch hat seine Grundlage in §§ 140b PatG, 242, 259 BGB i.V.m. Art. 64 EPÜ.

   Soweit die Beklagte Angaben zu den in Deutschland verkauften Einheiten gemacht hat, hat die Klägerin berechtigterweise diese Teilerfüllung des Auskunftsanspruchs nicht akzeptiert.

4. Der zugesprochene Vernichtungs- und Rückrufsanspruch hat seine Grundlage in § 140 a Abs. 1 S. 1 PatG bzw. § 140 a Abs. 3 S. 1 PatG, jeweils i.V.m. Art. 64 EPÜ. Der Rückrufanspruch erstreckt sich nach der Rechtsprechung des Oberlandesgerichts Karlsruhe auf gewerbliche Abnehmer einschließlich gewerblicher Endabnehmer, nicht aber auf sonstige Endabnehmer.

IV.

Der gerichtlichen Durchsetzung der Unterlassungs-, Rückruf- und Vernichtungsansprüche stehen in Anwendung der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs in der Rechtssache Huawei./. ZTE (EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015 – C-170/13, GRUR 2015, 764 = ECLI:EU:C:2015:477 idF des Berichtigungsbeschlusses vom 15. Dezember 2015, ECLI:EU:C:2015:817) kartellrechtliche Gründe nicht entgegen.

I. Die Kammer hat ihr Verständnis des Urteils des Gerichtshofs der Europäischen Union in der Sache Huawei Technologies/ZTE im Urteil vom 29. Januar 2016 - 7 O 66/15 (veröffentlicht bei juris) dargelegt und hält nach nochmaliger Überprüfung der dort vertretenen Rechtsauffassung an dieser Begründung fest. Aus Sicht der Kammer betont der Gerichtshof, dass das aus einem Patent fließende Ausschließlichkeitsrecht nur unter ganz besonderen Umständen nicht mit der Verletzungsklage durchsetzbar ist. Daraus folgt, dass die entsprechenden tatsächlichen Umstände, aus denen sich die Suspendierung des Patentrechts ergeben soll, von dem in Anspruch genommenen (angeblichen) Verletzer vorzutragen und wenn die Umstände im Streit stehen, auch zu beweisen sind.

Der Gerichtshof entwickelt aus Sicht der Kammer in seinem Urteil ein Konzept, dass es dem zur Entscheidung berufenen Gericht ermöglichen soll, das Verhalten des Inhabers des SEP auf der einen Seite sowie des angeblichen Verletzers auf der anderen Seite daraufhin zu bewerten, ob sich die Durchsetzung der auf das SEP gestützten Unterlassungs- und Rückrufanträge als ungerechtfertigter Marktmachtmissbrauch und Aufbau eines insoweit zu unterbindenden Drucks in der Verhandlungssituation zu bewerten ist oder als gerechtfertigte Reaktion auf eine vom (angeblichen) Verletzer verfolgte Verzögerungstaktik. Hingegen zielt die Entscheidung des Gerichtshofs nach der Überzeugung der Kammer nicht darauf ab, die Verletzungsgerichte mit der Bestimmung der FRAND-Bedingungen zu belasten, wenn im Verfahren der Unterlassungs- und Rückrufanspruch durchgesetzt werden soll und es nicht gerade um die Zahlung einer FRAND-Lizenzgebühr im Betragsverfahren geht.

Zu diesem Zweck hält es der Gerichtshof für erforderlich, dass der Patentinhaber in einem ersten Schritt vor der Erhebung einer auf Rückruf und Unterlassung gerichteten Klage, die für den angeblichen Verletzer einen erheblichen Verhandlungsdruck aufbaut, einen angeblichen Verletzer auf die ihm vorgeworfene Patentverletzung hinweist und dabei das SEP bezeichnet sowie angibt, auf welche Weise es verletzt sein soll. Jedenfalls wird der Patentinhaber das mit der Klage geltend gemachte und von ihm als standardessentiell deklarierte Patent mit seiner Patentnummer bezeichnen und angeben müssen, dass dieses Patent bei der betreffenden Standardisierungsorganisation als standardessentiell deklariert wurde. Soweit der Patentinhaber zudem angeben soll, auf welche Weise das Patent verletzt sein soll, muss der Hinweis dem Verletzer deutlich machen, für welchen Standard das Patent essentiell ist und aufgrund welcher Umstände der Patentinhaber davon ausgeht, dass der angebliche Patentverletzer von der Lehre des Patents Gebrauch macht. Jedenfalls ist dafür erforderlich, dass der Patentinhaber benennt, welche technische Funktionalität der angegriffenen Ausführungsform vom Standard Gebrauch macht. Der angebliche Verletzer

wird regelmäßig nämlich im Bilde darüber sein, dass sein Produkt einem Standard gemäß ausgebildet ist. Daher dürfte ein bloßer Hinweis, der angebliche Verletzer stelle nach dem Standard arbeitende Produkte her oder vertreibe diese und verletze deshalb das Patent, nicht ausreichend sein. Vielmehr muss der angebliche Verletzer durch den Hinweis in die Situation versetzt werden, die Schutzrechtslage selbständig prüfen (lassen) zu können. Aufgrund der Vielzahl der technischen Funktionalitäten, die regelmäßig in einem Standard enthalten sind und die gerade die vom Gerichtshof angesprochene Unübersichtlichkeit bei der Beurteilung der Schutzrechtslage begründet, wird es erforderlich sein, dass der SEP-Inhaber jedenfalls die Kategorie der technischen Funktionalität des Standards in einer solchen Weise benennt, dass der vermeintliche Verletzer nun wieder der grundsätzlich ihm obliegenden Pflicht, die Schutzrechtslage zur prüfen, gerecht werden kann. Wie detailliert dieser Hinweis zu erfolgen hat, kann nur nach den jeweiligen Umständen des Einzelfalls entschieden werden. Hierbei wird insbesondere einzustellen sein, welche Technologiekenntnisse beim Patentverletzer vorhanden sind bzw. inwieweit er sich solche Kenntnisse in zumutbarer Weise durch professionellen Rat zu verschaffen hat. Aus Sicht der Kammer sind zur Darlegung des Verletzungssachverhalts in einer den Anforderungen des Gerichtshofs entsprechenden Weise grundsätzlich jedenfalls – ohne hierauf beschränkt zu sein – die auch im Rahmen von Lizenzvertragsverhandlungen nach den geschäftlichen Gepflogenheiten sonst üblichen Claim-Charts ausreichend, die den geltend gemachten oder einen ihm verwandten Anspruch des Klagepatents, der gleichfalls die entscheidenden Merkmale aufweist, gegliedert nach Anspruchsmerkmalen den entsprechenden Stellen im Standard gegenüberstellen, ohne dass hierbei die Anforderungen der Schlüssigkeitsprüfung einer Verletzungsklage erfüllt werden müssen. Insoweit ist in der Regel ausreichend, dass der angebliche Verletzer den vom SEP-Inhaber erhobenen Vorwurf jedenfalls bei Hinzuziehung externen oder internen technischen Sachverstandes nachvollziehen kann.

Entsprechendes gilt für die weitere Obliegenheit des SEP-Inhabers, der zudem vor Klageerhebung dem angeblichen Patentverletzer – sofern dieser im Grundsatz seinen Willen zum Ausdruck gebracht hat, überhaupt Lizenz nehmen zu wollen – ein konkretes schriftliches Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen zu unterbreiten und insbesondere die Lizenzgebühr und die Art und Weise ihrer Berechnung anzugeben hat. Vor dem Hintergrund des zuvor geschilderten Verständnisses, das die Kammer zu der Entscheidung des Gerichtshofs entwickelt hat, ist hierfür erforderlich, dass es sich um ein annahmefähiges Vertragsangebot handelt, das die vertragswesentlichen Bedingungen enthält. Soweit der Gerichtshof ausführt, dass der Patentinhaber ein konkretes schriftliches Lizenz-Angebot zu FRAND-Bedingungen zu unterbreiten hat, bedeutet dies nicht, dass das Verletzungsgericht für den Fall, dass der (angebliche) Patentverletzer – wie regelmäßig – in Abrede stellt, dass dieses Angebot FRAND-Kriterien entspricht, gehalten ist, nunmehr nach objektiven Gesichtspunkten zu entscheiden, ob das Angebot des SEP-Inhabers tatsächlich FRAND ist oder nicht. Denn hierdurch würde der Verletzungsprozess gerade wieder mit der Bestimmung belastet, welche Lizenzhöhe exakt und sonstigen Vertragsbedingungen ganz

genau diesen Kriterien entsprechen, was aus Sicht der Kammer nicht das Anliegen des Gerichtshofs war. Kartellrechtswidrig und ersichtlich nicht FRAND ist ein Angebot erst dann, wenn es sich unter Berücksichtigung der konkreten Verhandlungssituation und insbesondere der Marktgegebenheit als Ausdruck von Ausbeutungsmissbrauch darstellt. Dies bedeutet freilich nicht, dass der Patentinhaber sich mit der bloßen Behauptung begnügen dürfte, seine Forderung sei fair, vernünftig und nicht diskriminierend.

Der Patentinhaber hat vielmehr dabei die Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühr so anzugeben, dass hierin deutlich wird, aus welchen darzulegenden Gründen er von einer Erfüllung der FRAND-Kriterien ausgeht. Nach Auffassung der Kammer wird der SEP-Inhaber den angeblichen Verletzer deshalb in die Lage versetzen müssen, anhand objektiver Kriterien nachzuvollziehen, warum der SEP-Inhaber zu der Überzeugung gelangt, dass das von ihm unterbreitete Angebot FRAND-Kriterien entspricht. Hierfür ist nicht ausreichend, dass der SEP-Inhaber bei einem Stücklizenzvertrag schlicht den pro Einheit zu zahlenden Betrag angibt, ohne zu erläutern, weshalb dieser Betrag nach seiner Ansicht FRAND-Bedingungen entspricht. Insoweit wird er den Betrag gegenüber dem vermeintlichen Verletzer in geeigneter Weise transparent zu machen haben, etwa durch Vortrag zu einem in der Vertragspraxis gelebten und von Dritten akzeptierten Standardlizenzprogramm oder unter Heranziehung anderer Bezugsgrößen, aus denen die geforderte Lizenzgebühr abgeleitet wird, wie etwa aus einer Poollizenzgebühr, die in der Praxis für einen Patentpool von Dritten gezahlt wird, der auch für den fraglichen Standard relevante Patente umfasst.

Der Verletzer muss auf dieses Angebot reagieren, selbst wenn es seiner Auffassung – wie regelmäßig – nicht den FRAND-Kriterien entspricht (ebenso im Ergebnis LG Mannheim, Urteil vom 27.11.2015 - 2 O 106/14 Seite 51 bei (bb) und LG Düsseldorf, Urteil vom 3. November 2015 - 4a O 144/14). Eine Ausnahme hiervon ist nach der Auffassung der Kammer allein in solchen Fällen zu machen, in denen sich das Angebot des SEP-Inhabers bereits bei summarischer Prüfung evident als nicht FRAND und mithin als Missbrauch einer beherrschenden Stellung des SEP-Inhabers darstellt. Dieses Gegenangebot ist alsbald zu unterbreiten, da der Gerichtshof dem angeblichen Patentverletzer keine Verzögerungstaktik zugestehen will. Mithin muss vom angeblichen Verletzter auf das konkrete schriftliche Angebot des SEP-Inhabers so schnell reagiert werden, wie dies nach den Umständen des Einzelfalls bei Anwendung der in dem Bereich anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten und des Grundsatzes von Treu und Glauben von ihm erwartet werden kann.

Schlägt der SEP-Inhaber dieses Angebot aus und hat der angebliche Verletzer das SEP bereits benutzt, bevor ein Lizenzvertrag geschlossen wurde, verlangt der Gerichtshof, dass er ab dem Zeitpunkt der Ablehnung des Gegenangebots eine angemessene Sicherheit etwa durch Beibringung einer Bankgarantie oder durch Hinterlegung leistet. Die Berechnung der Sicherheit muss unter anderem die Zahl der vergangenen Benutzungshandlungen in Bezug auf das SEP umfassen, für die der angebliche Verletzer eine Abrechnung vorlegen können

muss. Diese Sicherheit muss zudem den in dem betreffenden Bereich anerkannten Gepflogenheiten entsprechen.

I. Bei Zugrundelegung dieser Maßstäbe ist die Klägerin vorliegend nicht aus kartellrechtlichen Gründen gehindert, die mit der Klage verfolgten Ansprüche insbesondere auf Unterlassung, Rückruf/Entfernung aus den Vertriebswegen und Vernichtung durchzusetzen, so dass letztlich offen bleiben kann, ob das Klagepatente der Klägerin eine marktbeherrschende Stellung vermittelt.

a) Ob diese Maßstäbe der Kammer vor dem Hintergrund des Beschlusses des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 31. Mai 2016, Az.: 6 U 55/15, der meint, dass eine Evidenzkontrolle des Angebots des SEP-Inhabers einerseits nicht ausreichend sei, andererseits aber ausführt, dem SEP-Inhaber sei bei der Beurteilung, was FRAND sei, ein Entscheidungsspielraum zuzugestehen, und der lediglich eine summarische Prüfung im Rahmen eines Antrags auf einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung aus einem erstinstanzlichen Urteil betrifft, einer Überprüfung unterzogen werden müssen, kann vorliegend offen bleiben. Denn im konkreten Fall hat die Beklagte ihre Lizenzbereitschaft nicht rechtzeitig zum Ausdruck gebracht.

b) Die Klägerin hat ihre Hinweispflicht nach den Maßgaben der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs erfüllt. Bereits mit Schreiben vom 28.07.2015 (Anlage 4g) hat die Klägerin der X SAS die betroffenen Patente und Mobilstationen bezeichnet. Sie hat ferner eine Liste vorgelegt, in der für jedes der Patente Abschnitte aus den Standards genannt werden, aus denen sich die Patentverletzung ihrer Ansicht nach ergibt. So wird etwa in der Liste der LTE-Patente (dort No. 13, Anhang 3 zu dem Schreiben aus Anlage K 4g) für das hiesige Klagepatent der einschlägige Patentanspruch 7 genannt und auf das Standarddokument TS 36.321, Version 9.6.0 (Anlage KA 3c), dort Abschnitt 5.4.3 verwiesen. Dieser mit „*Multiplexing and assembly*" überschriebene Abschnitt enthält in seinem mit „*Logical channel prioritization*" überschriebenen Unterabschnitt 5.4.3.1 die im Tatbestand eingeblendete Textpassage. Aus dieser Textpassage lassen sich die wesentlichen Informationen für die Patentverletzung gewinnen. In Unterabschnitt 5.4.3.2 wird ausgeführt, dass die Prozedur aus 5.4.3.1 für das Multiplexen von MAC Steuerelementen und MAC SDUs in eine MAC PDU durch die Mobilstation verwendet werden soll. Weitere Hinweise auf die Funktionsweise des LTE-Standards waren vor diesem Hintergrund nicht erforderlich. Auch unter Berücksichtigung des Umstands, dass es sich um eine relativ junge Gesellschaft handelt, die die Mobiltelefone auch nicht selbst herstellt, war es der X SAS möglich, ggf. unter zumutbarer Inanspruchnahme von Hilfe von dritter Seite den Verletzungsvorwurf ausreichend nachzuvollziehen. Unschädlich ist insoweit, dass nicht auch die einzelnen Unterabschnitte des Abschnitts 5.4.3.1 aufgelistet sind, zumal sie sich anhand der Überschriften mit zumutbaren Aufwand finden lassen.

Bei alledem war zu berücksichtigen, dass es grundsätzlich Sache des Patentbenutzers ist, sich über die Schutzrechtslage in seinem Geschäftsfeld zu informieren. Gerade in Anbetracht der großen Zahl der SEP, die eine Übersicht erschweren und aufgrund der nicht sicher ist, dass der Patentbenutzer zwangsläufig weiß, dass er die Lehre eines rechtsbeständigen und standardessentiellen Patents benutzt (EuGH, a.a.O., Rn. 62), hat der Gerichtshof die Hinweispflicht aufgestellt, die den Patentbenutzer in die Lage verletzen soll, die Patentbenutzung zu erkennen. Die Verweise auf die wesentlichen Standardstellen in Anlage K 4g genügen hierfür vollauf. Auf ihrer Grundlage kann der Patentbenutzer prüfen, ob der Vorwurf der Patentverletzung vertretbar ist oder nicht, und dementsprechend entscheiden, ob er in Lizenzverhandlungen eintreten möchte.

Soweit in Lizenzverhandlungen die Überlassung von Claim-Charts üblich ist, führt diese Gepflogenheit jedenfalls nicht dazu, dass solche Claim Charts bereits zwingend im Rahmen des Verletzungshinweises zu überlassen wären, bevor der Patentbenutzer überhaupt seine Bereitschaft zum Ausdruck gebracht hat, einen Lizenzvertrag zur FRAND-Bedingungen abzuschließen.

c) Die X SAS hätte demnach entsprechend den Grundsätzen der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs auf den Verletzungshinweis reagieren müssen, indem sie ihre Bereitschaft zum Abschluss eines Lizenzvertrags nach FRAND-Bedingungen zum Ausdruck bringt. Diese Reaktion muss innerhalb einer angemessenen Zeitspanne erfolgen, da nach der Entscheidung des Gerichtshofs Verzögerungstaktiken des Patentbenutzers ebenso wie ein Überfall durch den Patentinhaber mit einer Unterlassungsklage zu unterbinden sind. Wie lange die Zeitspanne zu bemessen ist, innerhalb derer der Patentinhaber nach Treu und Glauben mit einer Reaktion rechnen darf und der Patentbenutzer deshalb seine Lizenzbereitschaft zum Ausdruck bringen muss, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab, insbesondere der Komplexität des erhobenen Verletzungsvorwurfs und dem Umfang der gelieferten Informationen. Dabei ist jedoch auch zu berücksichtigen, dass sich der Patentbenutzer dadurch, dass er seine Lizenzbereitschaft zum Ausdruck bringt, mit Blick auf den Verletzungsvorwurf und den Rechtsbestand in keiner Weise binden muss. Es ist ihm nämlich trotz erklärter Bereitschaft zum Abschluss eines Lizenzvertrags nach FRAND-Bedingungen unbenommen und stellt die zum Ausdruck gebrachte Lizenzbereitschaft nicht in Frage, wenn er während den Verhandlungen über die Erteilung von Lizenzen die Rechtsbeständigkeit der nämlichen Patente und/oder deren essentiellen Charakter für den einschlägigen Standard, und/oder ihre tatsächliche Benutzung anficht oder sich die Möglichkeit vorbehält, dies später zu tun (EuGH, a.a.O., Rn. 69). Hieraus folgt, dass sich der Patentbenutzer damit, seine Lizenzbereitschaft zum Ausdruck zu bringen, nicht Zeit lassen darf, bis er vollends von der Benutzung und dem Rechtsbestand des fraglichen Patents überzeugt ist. Ein solcher Bedeutungsinhalt kommt der Lizenzbereitschaftserklärung im Regime des Gerichtshofs gerade nicht zu. Vielmehr muss der vermeintliche Patentbenutzer nach dem Hinweis des

Patentinhabers bereits in einem frühen Stadium Farbe bekennen und zum Ausdruck bringen, ob er grundsätzlich bereit ist, Lizenz zu nehmen, so dass es für den Patentinhaber Sinn macht, ihm ein Angebot zu unterbreiten und die Art und Weise der Berechnung des Lizenzsatzes zu erläutern, um in konkrete Verhandlungen einzutreten, oder er dies grundweg ablehnt. Um eine so verstandene Lizenzbereitschaft zum Ausdruck zu bringen, bedarf es keiner Zeiträume, wie sie eventuell für eine eingehende Prüfung des Verletzungsvorwurfs und des Rechtsbestands im Einzelfall erforderlich sein mögen. Es reicht vielmehr ein Zeitraum, der es erlaubt, sich einen ersten Überblick über die Qualität des Verletzungsvorwurfs zu machen, insbesondere um zu beurteilen, ob der Vorwurf von vornherein abwegig ist oder ob er eine Berechtigung haben könnte, weil er nicht unvertretbar erscheint, zumal der Patentbenutzer sich nach dem Urteil des Gerichtshofs vorbehalten kann, die Patentverletzung und den Rechtsbestand einer gerichtlichen Prüfung zu unterziehen, was jedenfalls mit Blick auf den Verletzungstatbestand nur dann einen Sinn macht, wenn der Patentbenutzer von einer Patentverletzung nicht überzeugt ist. Ist ein Portfolio Gegenstand des Verletzungsvorwurfs und strebt der Patentbenutzer im Einklang mit den üblichen geschäftlichen Gepflogenheiten eine Lizenzvergabe am gesamten Portfolio an, ist es erst Recht nicht erforderlich, einen Zeitraum anzusetzen, der es ermöglichen würde, jedes einzelne Portfolio-Patent mit Blick auf seine Benutzung und seinen Rechtsbestand im Detail zu prüfen. Auch insoweit genügt ein Zeitraum, der dafür ausreicht, um sich einen Überblick über das Portfolio zu verschaffen, etwa indem ihrer Bezeichnung nach besonders relevante Patente vorrangig in den Blick genommen werden. Bei Zugrundelegen dieser Maßstäbe war die Lizenzbereitschaftserklärung der X SAS zu dem Zeitpunkt, als sie die Klägerin erreichte, verspätet.

aa) Die X SAS hatte ihre Lizenzbereitschaft nicht bereits im Rahmen der ersten Phase der Kontakte zwischen den Parteien bis zum Schreiben vom 28.07.2015 (Anlage K 4g) zum Ausdruck gebracht. Es kann daher offen bleiben, ob eine vor Erhalt eines den Anforderungen in Sachen Huawei ./. ZTE genügenden Hinweises, hier in Gestalt des Schreibens vom 28.07.2015, zum Ausdruck gebrachte Lizenzbereitschaft fortbesteht oder nach Erhalt des Hinweises nochmals wiederholt werden müsste.

Die X SAS hat auf die Terminsvorschläge der Klägerin nämlich entweder mit Absagen oder überhaupt nicht reagiert. Hierin kann kein Ausdruck einer Lizenzbereitschaft gesehen werden, da es auch Teil einer Verzögerungstaktik sein kann, Terminsvorschläge schlicht abzusagen oder hierauf nicht zu reagieren. Eine Lizenzbereitschaft kommt auch nicht dadurch zum Ausdruck, dass der E-Mail-Wechsel unter dem Betreff „*patent license discussion with X*" stattfand. Diesen Betreff hatte nämlich die Klägerin in der Ausgangs-E-Mail vom 19.11.2014 gewählt, mit der sie an eine ausstehende Reaktion auf ihr erstes Schreiben vom

13.10.2014 (Anlage K 4a) und den dortigen Vorschlag für ein Treffen vor Ende November 2014 erinnert hatte. Der Betreff wird bei einer Antwort automatisch übernommen. Aus dem Umstand, dass die X SAS die Antwortfunktion genutzt und den Standard-Antwort-Betreff übernommen hat, ohne ihn abzuändern, kann nicht abgeleitet werden, dass sie hierdurch ihre Lizenzbereitschaft zum Ausdruck gebracht hätte.

bb) Soweit die X SAS nach Erhalt des Schreibens vom 28.07.2015 (Anlage 4 g) mit dem Lizenzangebot und den technischen Hinweisen zum Verletzungsvorwurf mit Schreiben mit Datum vom 16.10.2015 (Anlage AR 8) reagiert und erklärt hat, relevante IP-Rechte Dritter vollumfänglich zu respektieren und stets bereit zu sein, nach Treu und Glauben Bedingungen einer Lizenz für werthaltige Patente zu verhandeln, war diese Reaktion verspätet. Wie von der Klägerin behauptet und von der Beklagten nicht bestritten, wurde das Schreiben erst am 20.10.2015 auf den Postweg zur Klägerin gegeben. Demnach kann die Klägerin das Schreiben frühestens am 21.10.2015 erhalten haben. Zwischen dem Schreiben und dem Verletzungshinweis vom 28.07.2015 lagen rund zweieinhalb Monate. Selbst unter Berücksichtigung des Umstands, dass der August Ferienmonat in Frankreich ist und dass die X SAS – zu Argumentationszwecken unterstellt – über keine eigene technische Erfahrung verfügt, wäre zu erwarten gewesen, dass sie ihre Bereitschaft, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen abzuschließen, deutlich vor dem 16.10.2015 zum Ausdruck bringt, da bis dahin ausreichend Zeit bestand, um den Sachverhalt in dem oben dargelegten Umfang zu prüfen.

Auch der Umstand, dass die Klägerin der X SAS unter dem 25.09.2015 ergänzend Claim-Charts überlassen hat, entbindet diese nicht davon, eine Reaktion zu zeigen. Die Überlassung zusätzlicher Informationen, die über das hinausgehen, was für einen Verletzungshinweis im Sinne des Huawei ./. ZTE-Urteils des Europäischen Gerichtshofs erforderlich ist, berührt nämlich den Umstand nicht, dass der Patentbenutzer bereits aufgrund des Hinweises in der Lage war, sich ein Bild zu machen, das ausreicht, um eine Lizenzbereitschaft zum Ausdruck zu bringen oder zu verneinen. Durch die Überlassung solcher zusätzlicher Informationen kann der Patentbenutzer nicht schlechter stehen, als wenn er sie nicht überlassen hätte. Ob im Einzelfall etwas anderes gilt, wenn sich auf der Grundlage der zusätzlichen Informationen ein völlig vom bisherigen Verletzungsvorwurf abweichendes Bild ergibt, so dass der Patentinhaber nach Treu und Glauben davon ausgehen muss, dass der Patentbenutzer von neuem in die Prüfung einsteigen muss, bedarf vorliegend keiner Entscheidung, da die Beklagte einen solchen Sachverhalt nicht behauptet und er auch sonst nicht ersichtlich ist. Im Übrigen hätte die X SAS der Klägerin auch mitteilen können, dass sie noch über mehr Zeit für die Prüfung der Unterlagen benötigt. Da sie

jedoch weder auf das Schreiben vom 28.07.2015 noch auf die E-Mail vom 25.09.2015 eine Reaktion gezeigt hat, musste sich der Klägerin der Eindruck aufdrängen, dass die X SAS kein Interesse an Lizenzverhandlungen hat. Eine Indikation von Seiten der X SAS vor dem Schreiben vom 16.10.2015, auch nur einen Gesprächsfaden aufnehmen zu wollen, ist weder vorgetragen, noch ersichtlich. Angesichts dieser Umstände kann der Klägerin nicht vorgeworfen werden, sie würde durch die Erhebung der Klage eine marktbeherrschende Stellung missbrauchen und kartellrechtswidrigen Druck aufbauen.

Vor diesem Hintergrund kommt es nicht darauf an, ob das Schreiben aus Anlage AR 8, das unstreitig erst am 20.10.2015 auf den Postweg zur Klägerin gegeben wurde, erst unter dem Eindruck des Erhalts einer französischen Klageschrift der Klägerin zu anderen Patenten am 19.10.2015 entstanden und zurückdatiert sein könnte, wie die Klägerin in den Raum gestellt hat.

cc) Ob auch eine verspätete Lizenzbereitschaftserklärung die Einreichung einer Unterlassungsklage hindert, bedarf vorliegend keiner allgemeinen Entscheidung. Jedenfalls dann, wenn der Patentinhaber im Zeitpunkt des Zugangs der verspäteten Lizenzbereitschaftserklärung bereits berechtigterweise Klage eingereicht hat, weil er die Anforderungen aus der Entscheidung Huawei ./.ZTE, die für die Phase bis zur Lizenzbereitschaftserklärung des Patentbenutzers gelten, erfüllt hat, ist er nicht gehalten, die eingereichte Klage anzuhalten. Ein solches Erfordernis lässt sich dem Urteil des Gerichtshofs in Sachen Huawei ./. ZTE nicht entnehmen. Die den Patentbenutzer treffenden Obliegenheiten würden entwertet, wenn er diese nach Klageeinreichung beliebig nachholen und damit der eingereichten Klage die Grundlage entziehen könnte. In diesem Fall würde es nämlich für den Patentbenutzer ohne signifikante Folgen bleiben, wenn er sich vor Klageeinreichung nicht auf Lizenzverhandlungen einlässt, und jeder Anreiz für außergerichtliche Verhandlungen ginge verloren. Zwar mag der Patentbenutzer die Kosten des Rechtsstreit tragen, wenn der Patentverletzer den Rechtsstreit daraufhin für erledigt erklärt. Hierbei handelt es sich indes um keinen so schwerwiegenden Nachteil, als dass er für den Patentbenutzer einen hinreichenden Anreiz begründen könnte, es nicht auf eine Klage ankommen zu lassen, sondern Lizenzverhandlungen aufzunehmen. Zum einen fallen diese Kosten nämlich nicht ins Gewicht, zumal dann nicht, wenn man sie als Preis dafür auffasst, auf die Chance, dass der Patentinhaber doch von einer gerichtlichen Durchsetzung absieht, zu spekulieren. Zum anderen ist es auch nicht gesichert, dass in jedem Mitgliedstaat der EU eine entsprechende Kostenregelung existiert. Darüber hinaus ist auch kein Grund ersichtlich, die Klageeinreichung durch den Patentinhaber als missbräuchlich zu werten, wenn der Patentbenutzer seine Lizenzbereitschaft nicht wie geschuldet zum Ausdruck gebracht hat und der Patentinhaber daher den Eindruck gewinnen musste, dass

der Patentbenutzer nicht lizenzwillig ist. Zeigt sich der Patentbenutzer nicht rechtzeitig lizenzwillig und kommt es daher zu Verzögerungen, gibt es keinen Grund, den Patentinhaber weiter von der Durchsetzung seines zeitlich ohnehin nur beschränkten Ausschließlichkeitsrechts auszuschließen. Im Einklang hiermit steht, dass der Europäische Gerichtshof (a.a.O., Rn. 65) betont, dass Verzögerungstaktiken auf Seiten des Patentbenutzers zu vermeiden seien. Schließlich ergibt sich auch daraus, dass sowohl der Hinweis des Patentinhabers auf die Patentverletzung als auch das konkrete Lizenzvertragsangebot und die Erläuterung der Art und Weise der Lizenzberechnung vor Klageerhebung erfolgen müssen, dass auch der Patentbenutzter seine Lizenzbereitschaft zwingend vor Klageerhebung zum Ausdruck bringen muss, da hierdurch überhaupt erst die vor Klageerhebung durch den Patentinhaber zu erfüllende Obliegenheit ausgelöst wird, ein konkretes Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen zu unterbreiten und insbesondere die Lizenzgebühr sowie die Art und Weise ihrer Berechnung zu erläutern. Eine Nachholung der Lizenzbereitschaftserklärung ist daher nicht möglich. Die Kammer sieht sich in dieser Auffassung dadurch bestärkt, dass der Gerichtshof insoweit durch Berichtigungsbeschluss klargestellt hat, dass sich die Worte „vor Klageerhebung" sowohl auf die Erläuterung zur Patentverletzung als auch auf Vorlage des Lizenzangebots und die Erläuterung der geforderten Lizenzgebühr beziehen, und damit das Erfordernis vor Klageerhebung nochmals betont hat, so dass auch der Zwischenschritt, nämlich dass der Patentbenutzer seine Lizenzbereitschaft zum Ausdruck bringt, vor Klageerhebung zu erfolgen hat.

Dabei versteht die Kammer den Begriff der Klageerhebung im Sinne der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs im Sinne von Klageeinreichung und nicht im Sinne der Klageerhebung nach ZPO, die erst mit Zustellung erfolgt. Es ist nämlich nichts dafür ersichtlich, dass der Gerichtshof zwischen der Einreichung der Klage und einer gerichtlichen Zustellung differenzieren wollte und erst die Zustellung kartellrechtlich bedenklich wäre. Da andere Mitgliedstaaten die deutsche Unterscheidung zwischen Einreichung und Zustellung der Klage nicht kennen, kann überdies nicht davon ausgegangen werden, dass der Gerichtshof den Begriff der Klageerhebung im Sinne der deutschen ZPO verwendet hätte. Auf die Besonderheiten der jeweiligen nationalen Prozessrechte kommt es auch nicht an, da das kartellrechtlich relevante Verhalten die gerichtliche Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs ist, unabhängig davon, durch wen und wann die Klage nach den nationalen Verfahrensordnungen der einzelnen Mitgliedsstaaten zugestellt wird. Vor diesem Hintergrund ist es daher ohne Belang, dass die

vorliegende Klage der Beklagten erst zugestellt wurde, nachdem die Klägerin das Schreiben vom 16.10.2015 erhalten hatte.

dd) Entgegen der Auffassung der Beklagten ist ihr das Verhalten der X SAS auch zuzurechnen. Es entspricht den üblichen Gepflogenheiten, dass in Konstellationen wie der vorliegenden, in der Portfolio-Patente in mehreren Schutzstaaten gelten und der Patentbenutzer eine Unternehmensgruppe ist, der in mehreren dieser Staaten ebenfalls patentbenutzende Produkte vertreibt, der Patentinhaber nicht an jede einzelne nationale Vertriebsgesellschaft der Unternehmensgruppe herantritt und für deren Vertriebsgebiet individuelle Lizenzverträge verhandelt, sondern dass die Lizenzverhandlungen mit der führenden Gesellschaft über eine weltweite Portfolio-Lizenz geführt werden, die dann auch den einzelnen gruppenangehörigen Gesellschaften zugutekommt. Soweit die Beklagte vorliegend geltend macht, sie habe bis zum 29.08.2016 nicht dem Konzernverbund der X SAS bzw. der Tinno angehört, da sie bis dahin einen Minderheitsgesellschafter mit 49 % Anteilen gehabt habe und Lizenzverträge ausweislich ihres Gesellschaftsvertrags zu den Beschlusspunkten gehörten, für die eine einstimmige Beschlussfassung durch die Gesellschafter vorgesehen sei, rechtfertigt dies keine andere Bewertung. Die Beklagte behauptet nämlich nicht, dass zwischen ihren Gesellschaftern oder zwischen ihr und der X SAS ein Dissens über die Frage des Abschlusses eines Lizenzvertrags bestanden habe, so dass sich in der Unternehmensgruppe kein einheitlicher Wille hätte bilden können.

Unerheblich ist auch, dass die Klägerin die X SAS und nicht die Mutter Tinno angesprochen hat, denn ausweislich der von der Klägerin dargelegten Umstände handelt es sich bei der X SAS um diejenige Gesellschaft innerhalb der X-Gruppe, die als Ansprechpartner in Lizenzsachen fungiert. Dem ist die Beklagte nicht hinreichend entgegengetreten, sondern hat lediglich vorgebracht, dass sie selbst nicht konzernverbunden sei.

ee) Ohne Bedeutung für die Frage, ob die Beklagte bzw. X SAS ihre Lizenzbereitschaft rechtzeitig zum Ausdruck gebracht hat, ist der Umstand, dass die Beklagte bzw. X SAS nach Klageerhebung ein Lizenzangebot vorgelegt, über die angeblichen Umsätze Auskunft erteilt und einen namhaften Betrag hinterlegt haben. Wie die Kammer bereits in anderem Zusammenhang entschieden hat, kann zwar das Verhalten der Beklagten nach Klageerhebung u.U. ein Indiz für ihre grundsätzliche vorgerichtliche Bereitschaft, in Lizenzvertragsverhandlungen mit der Klägerin einzutreten, gewertet werden. Dies setzt allerdings voraus, dass bereits vor Klageerhebung ein Verhalten stattgefunden hat, das eine solche Lizenzbereitschaft grundsätzlich zum Ausdruck bringt. Nur in einem solchen Fall kann die Bewertung dieses

Verhaltens als Lizenzbereitschaft weiter durch das Verhalten nach Klageerhebung bestätigt werden. Ein Verhalten nach Klageerhebung kann indes das Erfordernis, dass die Lizenzbereitschaft fristgemäß zum Ausdruck gebracht worden sein muss, nicht ersetzen.

d) Da die X SAS ihre Lizenzbereitschaft nicht rechtzeitig zum Ausdruck gebracht hat und die Klägerin daher berechtigterweise Klage erheben und ihre Klage auch weiter betreiben durfte, kommt es nicht darauf an, ob das Lizenzangebot der Klägerin FRAND-Bedingungen genügt und sie die Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühr vor Klageerhebung ausreichend erläutert hat, denn hierzu war sie nicht verpflichtet, da diese Obliegenheiten sie erst dann getroffen hätten, wenn die X SAS ihre Lizenzbereitschaft rechtzeitig zum Ausdruck gebracht hätte. Ist die Klage zulässigerweise erhoben, ist der Patentinhaber auch nicht verpflichtet, die ihn für die Phase vor Klageerhebung treffenden Obliegenheiten nachzuholen, wenn der Patentbenutzer nach Klageerhebung nunmehr die ihm obliegenden Verhaltensweisen nachträglich erfüllt. Denn auch insoweit gilt, dass ein Verstoß des Patentbenutzers gegen die ihn treffenden Verhaltensregeln andernfalls sanktionslos bliebe und daher kein Anreiz zu ihrer vorprozessualen Einhaltung bestünde, wenn der Patentbenutzer sie noch während des Gerichtsverfahrens nachholen und damit den Patentinhaber dazu zwingen könnte, einen Schritt zurück in die Phase der nach dem Konzept des Europäischen Gerichtshofs vor Klageerhebung angesiedelten Verhandlungen zu gehen, und ihn damit für geraume Zeit der Durchsetzung seiner Ausschließlichkeitsrechte berauben könnte.

e) Soweit die Klage auf Erteilung von Auskünften und Rechnungslegung sowie die Feststellung der Schadensersatzverpflichtung gerichtet ist, stehen der Geltendmachung dieser Ansprüche kartellrechtliche Gesichtspunkte von vornherein nicht entgegen (vgl. Huawei Technologies/ZTE (EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015 – C-170/13, GRUR 2015, 764 Rn. 72 ff. = ECLI:EU:C:2015:477 idF des Berichtigungsbeschlusses vom 15. Dezember 2015, ECLI:EU:C:2015:817).

V.

Der Rechtsstreit war nicht bis zur Entscheidung über die gegen das Klagepatent anhängige Nichtigkeitsklage auszusetzen. Die Entscheidung über die Nichtigkeitsklage ist zwar vorgreiflich im Sinne des § 148 ZPO. Die Kammer hat aber das ihr durch diese Vorschrift eingeräumte Ermessen dahingehend ausgeübt, dass von einer Aussetzung des Verletzungsprozesses abgesehen wird.

1. Die Kammer hat sich dabei von folgenden grundsätzlichen Überlegungen leiten lassen:

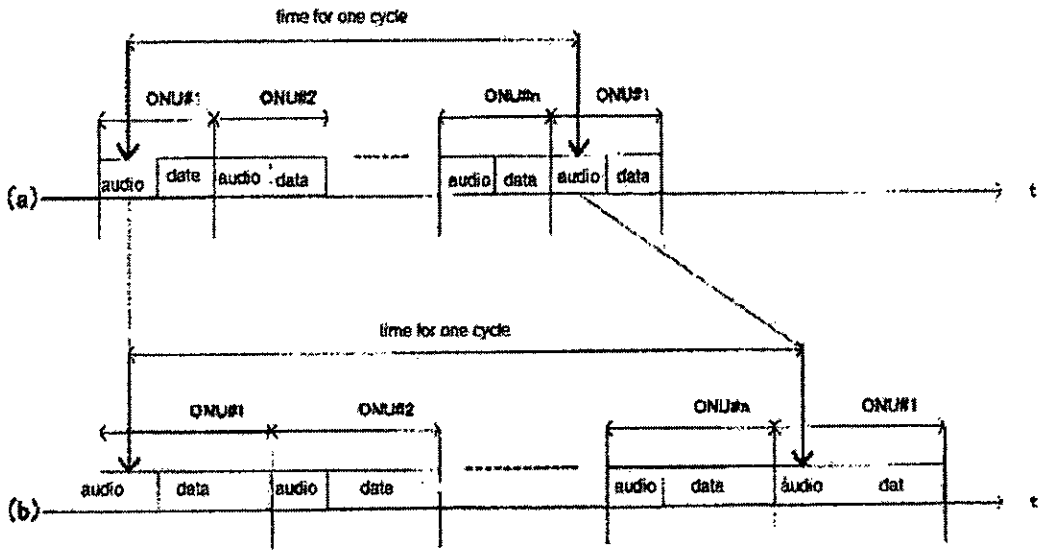
Um Missbräuche zu verhindern, ist ein Verletzungsprozess nur dann auszusetzen, wenn der voraussichtliche Erfolg des Einspruchs bzw. der Nichtigkeitsklage von der Beklagtenseite glaubhaft gemacht ist. Die bloße Möglichkeit der Vernichtung bzw. des Widerrufs des

Klagepatents genügt für eine Aussetzung dagegen grundsätzlich nicht. Allgemein ist große Zurückhaltung mit der Anordnung der Aussetzung geboten, damit nicht im Wege der Aussetzung letztlich eine Suspendierung des dem Patentinhaber durch die Patenterteilung auch für die Gerichte bindend verliehenen Verbotsrechts für eine erhebliche Zeitspanne erreicht wird. Es ist daher grundsätzlich eine hinreichende, mithin überwiegende Wahrscheinlichkeit der fehlenden Rechtsbeständigkeit des Klagepatents zu verlangen (vgl. BGH, GRUR 2014, 1237 Rn. 4 – Kurznachrichten *Grabinski/Zülch* in Benkard, PatG, 11. Aufl. 2015, § 139 Rn. 107).

2. Bei Anlegung dieser Maßstäbe ist die Kammer zu der Entscheidung gelangt, im vorliegenden Fall nicht auszusetzen. Von einer hinreichenden Wahrscheinlichkeit, dass das Klagepatent im Nichtigkeitsverfahren vernichtet werden wird, ist die Kammer nicht überzeugt.

   a) Die Beklagte stützt ihren Neuheitsangriff zunächst auf die Entgegenhaltung JP2004-153539 (NK 1 der Nichtigkeitsklage, im Folgenden NK 1). Ihren diesbezüglichen Ausführungen kann die Kammer indes keine hinreichenden Erfolgsaussichten im Nichtigkeitsverfahren beimessen.

      aa) NK 1 offenbart ein Netzwerk, in dem mehrere untergeordnete Stationen (sog. *slave stations*) über einen *master* an ein höheres Netz angebunden sind. Die untergeordneten Stationen verfügen über Warteschlangen für Daten mit höherer und niedriger Priorität, in die empfangene Datenpakete über einen entsprechenden Sortierer geleitet werden. Die untergeordneten Stationen setzen zudem Datenpakete zu sog. Frames für die Übertragung an den Master zusammen. Dabei kann auf Anweisung des Masters der Übertragungsmodus geändert werden. In einem der Übertragungsmodi überträgt jede untergeordnete Station (bezeichnet als ONU#1 bis ONU#n) in ihrem Frame nach hinzugefügten Overhead- und OAM-Daten zunächst die hoch- und danach die niederprioritären Daten. Die einzelnen untergeordneten Stationen übermitteln die Frames nacheinander, ein Durchlauf durch alle Stationen wird dabei als Vorgang/Zyklus bezeichnet. Stehen viele Daten zur Übertragung an, verlängert sich die Übertragungszeit der einzelnen untergeordneten Stationen (es werden mehr Daten übertragen) und die Gesamtzeitzyklus entsprechend, was Fig. 6 a veranschaulicht.



Nach den Behauptungen der Beklagten sollen durch eine längere Zykluszeit des aktuellen Zyklus bei entsprechendem Datenanfall mehr Daten in den Warteschlangenspeichern anfallen, die auf den Beginn des nächsten Zyklus warten müssten und die dann die Größe der im folgenden Zyklus übermittelten Datenmenge beeinflussten. Die wartenden Daten seien verzögert und die Wartezeit sei ein Verzögerungskriterium des Warteschlangenspeichers im Sinne der Merkmal-Gruppe f.

bb) Die Kammer vermag den Ausführungen der Beklagten nicht mit der notwendigen Sicherheit eine neuheitsschädliche Vorwegnahme der Lehre des Klagepatents zu entnehmen. Dabei ist zunächst festzuhalten, dass für die Beurteilung der Neuheitsschädlichkeit der NK 1 die zwischen den Parteien umstrittene Frage, ob die von der Beklagten herangezogene Figur 6 zur erfindungsgemäßen Lehre der Entgegenhaltung gehört, unerheblich ist. Für die Ermittlung des Offenbarungsgehalts der NK 1 kommt es nur darauf an, ob die Entgegenhaltung die technische Lehre des Klagepatents unmittelbar und eindeutig offenbart. Ob dies als beanspruchte Erfindung oder als (vermeintlicher) Teil des Stands der Technik geschieht, ist hierfür grundsätzlich unerheblich.

Die Kammer vermag jedoch auf der Grundlage der Ausführungen der Beklagten schon nicht die Offenbarung von zwei Regeln zu erkennen, da der Frame stets nach derselben Regel, nämlich nach Priorität (zuerst alle hochpriorisierten und dann alle niedrigpriorisierten Daten), zusammengesetzt wird. Die Beklagte hat nicht hinreichend aufgezeigt, dass es neben dieser rein prioritätsbasierten Regel noch eine zweite geben würde, so dass nicht alle Plätze nach Priorität vergeben werden, und der Multiplexer entsprechend in der Lage wäre, nach zwei Regeln zu arbeiten. Eine zweite Regel kann insbesondere nicht darin gesehen werden, dass die Übertragungszeit (*polling time*) nach NK 1 begrenzt sein kann, so dass nicht mehr alle niedrigprioritären Daten übertragen werden. Diese Begrenzung ändert

nämlich nichts daran, dass zunächst alle hoch- und dann – solange noch Platz ist – die niedrigpriorisierten Daten übertragen werden.

Überdies ist auch Merkmalsgruppe f nicht offenbart. Die Beklagte behauptet, dass sich bei entsprechenden Datenanfallraten während eines Zyklus Daten in den Warteschlangenspeichern ansammelten, die auf den nächsten Zyklus warteten. Beim nächsten Zyklus sei die Menge der übertragenen hoch- und niedrigpriorisierten Daten daher jeweils von der Menge der wartenden Daten abhängig. Für die Offenbarung einer technischen Lehre kommt es nicht darauf an, ob die Wartezeit bis zum nächsten Zyklus als Verzögerungskriterium für den jeweiligen Warteschlangenspeicher und die anstehenden Daten als relativ zu diesem Kriterium verzögert gewertet werden könnten, wenn sich beim Betrieb der Vorrichtung aus NK 1 die von der Beklagten behaupteten Konstellationen einstellen. Vielmehr müssten diese Umstände als zu einer technischen Lehre gehörend unmittelbar und eindeutig offenbart sein. Die Beklagte hat keine Beschreibungsstelle aufgezeigt, in der die von ihr behaupteten Konstellationen geschildert würden. Ob der Fachmann dies gleichwohl erkennt und mitliest, vermag die Kammer in Ermangelung eigener Sachkunde nicht zu beurteilen.

b) Auch die Darlegungen der Beklagten zu einer Neuheitsschädlichkeit der Entgegenhaltung NK 2 bzw. NK 2a / 2b /2c können die Kammer nicht von einer hinreichenden Erfolgswahrscheinlichkeit der Nichtigkeitsklage überzeugen. Dabei kann dahinstehen, ob die Dokumente nicht zu berücksichtigende unfertige Entwicklungen, die die beanspruchte Lehre noch nicht als ausführbare Anweisung enthalten, darstellen, wie die Klägerin meint.

aa) Die Entgegenhaltungen befassen sich mit dem Festlegen und Zuweisen von Übertragungsraten („*Rate Scheduling*") auf einem bestimmten Kanal von Mobilstation zu Basisstation. Dabei sprechen sie zwei Vorgehensweisen an, nämlich ein „*per UE basis rate scheduling*" und ein „*per priority queue basis rate scheduling*".

bb) Den Darlegungen der Beklagten zur Vorgehensweise „*per UE basis rate scheduling*" vermag die Kammer nicht die Offenbarung von zwei Regeln entnehmen. Die Darstellungen in der Entgegenhaltung sind recht abstrakt. Insbesondere wird nicht konkret aufgezeigt, nach welcher bzw. ggf. welchen konkreten Regeln der sog. TFC die MAC-e PDU bestückt. Der bloße Verweis auf die pauschale Formulierung, dass der TFC-Auswahl-Algorithmus die Transportformatkombination (TFC) basierend auf der Warteschlangengröße jeder Prioritätswarteschlange, der verbleibenden Übertragungsleistung und der garantierten Datenrate auswähle (vgl. NK 2, S. 2 oben), und auf die Fig. 1 aus Anlage NK 2, die die genannten Größen als Eingangsgrößen in die „black box" TFC Selection ausweisen, sowie die Behauptung, die „TFC Selection" sei im

Prioritätszeitpunkt als Teil des UMTS-Standard Release 99 Wissen des Fachmanns gewesen, versetzen jedenfalls die Kammer, die über keine eigene Sachkunde verfügt, nicht dazu in die Lage, eine hinreichende Wahrscheinlichkeit einer neuheitsschädlichen Vorwegnahme der Lehre des Klagepatents anzunehmen.

Auch mit Blick auf das *„per priority queue basis rate scheduling"* hat die Beklagte nicht hinreichend aufgezeigt, dass das Multiplexgerät der Mobilstation nach zwei verschiedenen Regeln zu arbeiten in der Lage ist. Dem Vortrag der Klägerin, dass der Multiplexer strikt nach vorgegebener Datenrate auswähle, ist die Beklagte nicht hinreichend entgegengetreten. Wie sich den Bullet Points über der Fig. 2 aus NK 2 entnehmen ist, gibt die Basisstation (Node B) für jede Prioritätswarteschlange eine Datenrate vor und der TFC-Auswahl-Algorithmus wählt die Transportformatkombination (TFC) basierend allein auf der von der Basisstation gewährten Datenrate für jede Prioritätswarteschlange. Auf welche konkrete Art und Weise die Datenraten bestimmt werden, insbesondere ob der Bestimmung zwei Regeln zugrunde liegen, wird in der Entgegenhaltung jedenfalls für die nicht sachkundig besetzte Kammer nicht hinreichend deutlich.

c) Die Kammer kann sich auch mit Blick auf die Entgegenhaltung WO 03/034242 (NK 3 der Nichtigkeitsklage, im Folgenden NK 3) keine Überzeugung dahin bilden, dass diese die Lehre der Klagepatents neuheitsschädlich trifft.

aa) NK 3 befasst sich mit der Zuteilung einer Ressource (z.B. eines Speichers) an unterschiedliche Anfragen, die über verschiedene Kanäle zu der Vorrichtung gelangen.

bb) Die Kammer vermag den von der Beklagten angeführten Stellen der Entgegenhaltung nicht zu entnehmen, inwieweit dort Datenpakete zu neuen Datenpaketen zusammengesetzt werden. Soweit für die Kammer ersichtlich, behandelt die Entgegenhaltung den Zugriff von *„requests"* auf eine Ressource, insbesondere in welchem Umfang die *requests* auf die Ressource zugreifen dürfen. So heißt es etwa in Abschnitt [0014] zur Funktion der sog. *arbitration unit*, in der die Beklagte offenbar den Multiplexer sieht, dass dieser, wenn mehr als ein Kanal eine *request* habe, die auf den Service warte, den Kanal auswähle, der Zugang zu dem Service erhalte, wobei bei dieser Auswahl die Zuteilungshistorie und die gewünschte Quality-of-service-Information benutzt würden. Auch in Abschnitt [0005] der Entgegenhaltung heißt es lediglich, dass die *requests* der einzelnen, nach den dort angegebenen Kriterien ausgewählten Kanäle zum Zuge kämen. Inwieweit in der Entgegenhaltung *requests* zu neuen zusammengesetzt werden, erscheint jedenfalls der nicht fachkundigen Kammer nicht hinreichend klar. Vielmehr scheint jede *request* nach ihrer Auswahl sofort ausgeführt zu werden und nicht in einem „Request-Bündel" gesammelt zu werden zu werden.

Bei der *arbitration unit* dürfte es sich mithin um eine Vorrichtung handeln, die die *requests*, die bearbeitet werden, aussucht und nicht zu neuen Einheiten zusammensetzt. Die Kammer verkennt nicht, dass die Ressource, auf die die *requests* zugreifen, auch ein Speicher, etwa ein DRAM-Speicher, sein kann und dass Gegenstand eines *request* auch das Speichern von Daten auf diesem DRAM-Speicher sein kann, so dass die *arbitration unit* in diesem Ausführungsbeispiel auch eine Auswahlentscheidung unter mehreren Speicheranfragen, die sich auf Datenpakete beziehen, zu treffen hat. Gleichwohl vermag die nicht sachkundige Kammer nicht mit der notwendigen Sicherheit zu beurteilen, ob der Fachmann die *arbitration unit* in diesem Fall als Mulitiplexer, der Datengruppen zusammensetzt, auffasst. Selbst wenn man die auf dem DRAM-Speicher abgespeicherten Daten als Datengruppe ansehen wollte, die von einem Multiplexer zusammengesetzt wurden, ist nicht ersichtlich, wo in der Entgegenhaltung Mittel zum Übertragen eben dieser Datengruppe offenbart sind. Für die Kammer ist auch nicht erkennbar, dass die abzuspeichernden Datenpakete, für die die *arbitration unit* eine Auswahl für den Speicherzugriff trifft, bereits vor der Übertragung an den DRAM-Speicher zu einer Datengruppe zusammengesetzt würden, wie die Beklagte ohne Anführung einer Fundstelle im Termin vorgebracht hat. Insbesondere dürfte das bloße kontinuierliche Weiterleiten der zu speichernden Daten in der ausgewählten Reihenfolge keine Datengruppe darstellen.

d) Auch auf der Grundlage der Entgegenhaltung US 2002/0191622 A 1 (NK 4 der Nichtigkeitsklage, im Folgenden NK 4) kann die Kammer keine hinreichende Wahrscheinlichkeit feststellen, dass das Klagepatent wegen fehlender Neuheit vernichtet werden wird.

aa) Die Entgegenhaltung NK 4 hat das Routing von Internetdatenverkehr zum Gegenstand. Die Abläufe werden in den nachstehend eingeblendeten Figuren 2 und 5 aus der Entgegenhaltung NK 4 visualisiert, wobei die Fig. 5 eine nähere Darstellung des in der Fig. 2 enthaltenen „*differentiated queuing block 240*" zeigt.

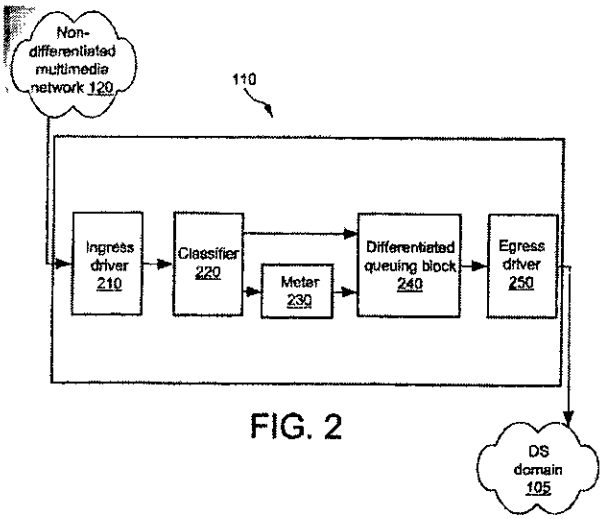


FIG. 2

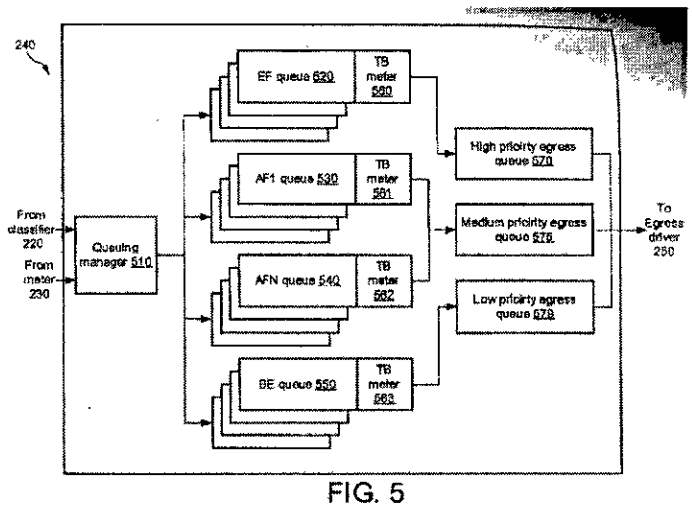


FIG. 5

Der Entgegenhaltung NK 4 lässt sich entnehmen, dass der *Queuing manager 510* verschiedenen Warteschlangenspeicher zuteilt. Die *Expedited Forwarding (EF) queue* enthält etwa Datenpakete mit geringen Latenzzeit-Anforderungen, die *Assured Forwarding (AF) queues*, von denen es N Stück gibt, enthalten dagegen Daten, die ein gewisse Bandbreite benötigen. Die *Best Effort (BE) queue* enthält unmarkierte Verkehrsdaten. Die vorgenannten Warteschlangen sind sog. primäre Warteschlangen, denen sog. sekundäre Warteschlangen nachgeordnet sind (vgl. NK 4, Abschnitte [0044] und [0045]), die als FIFO Speicher funktionieren. Der *EF queue* ist als sekundäre Warteschlange die *High priority egress queue 570* nachgeordnet, den *AF queues* entsprechend die *Medium priority egress queue 575* und der *BE queue* entsprechend die *Low priority egress queue* 579. Eine Zusammenstellung einer Datengruppe erfolgt in diesem Stadium – soweit ersichtlich – nur bei dem Zusammenstellen der Daten aus den N-Stück *AF queues* in der *Medium priority egress queue.* So dann werden Daten aus der *High, Medium* und *Low priority egress queue* zu einer Datengruppe im Ausgangsspeicher zusammengesetzt. Der *EF queue* ist eine maximale Datenrate bzw. Bandbreite zugewiesen, die bedient wird, bis der Ausgangsspeicher (*transmit ring*) voll ist oder die maximale Datenrate verbraucht ist oder keine zu übertragenden Daten mehr vorhanden sind. Nach dem Verständnis der Kammer wird die Datenrate bei der *EF queue* als maximale Datenrate bezeichnet, weil es vorkommen kann, dass die höchstpriorisierte *EF queue* weniger Daten hat, als die ihr zugewiesene Datenrate zuließe. Etwaige nicht zum Zug gekommene Daten verbleiben in der *High priority egress queue* und werden dort gespeichert. Danach kommen die *AF queues* zum Zuge, denen eine Mindest-Datenrate zugewiesen ist und die etwaige nicht verbrauchte Bandbreite der *EF queue* ebenfalls nutzen können. Nach dem Verständnis der Kammer wird die Datenrate bei den *AF queues* als minimale Datenrate bezeichnet, weil sich diese Datenrate ggf. durch

die Nutzung nicht genutzter Bandbreite der *EF queue* erhöhen kann, nicht weil es dort keine Obergrenze geben würde. Etwaige Daten, die nicht zum Zuge gekommen sind, weil der Ausgangsspeicher voll ist, verbleiben in der *Medium priority egress queue* und werden dort gespeichert. Die Beklagte zeigt nicht auf, dass diese nicht zum Zuge gekommenen Daten bei der nächsten Übertragungsrunde nicht entsprechend ihrer Prioritätsklasse übertragen würden. Insbesondere zeigt die Beklagte nicht auf, dass diese verzögerten Daten etwa vorrangig vor Daten aus der höchsten Prioritätsklasse übertragen würden. Soweit ersichtlich, werden sie aufgrund der FIFO-Eigenschaft der *Medium priority egress queue* bei der nächsten Übertragungsrunde lediglich vorrangig vor den neu hinzukommenden Daten der *AF queues* bedient. Die *BE Queue* kommt erst danach zum Zuge und zwar in dem Umfang, wie noch Kapazität im Ausgangsspeicher vorhanden ist. Etwaige nicht zum Zuge gekommene Daten verbleiben in der *Low priority egress queue* und werden dort gespeichert. Die Beklagte zeigt auch hier nicht auf, dass diese nicht zum Zuge gekommenen Daten bei der nächsten Übertragungsrunde nicht entsprechend ihrer Prioritätsklasse übertragen würden. Insbesondere zeigt die Beklagte nicht auf, dass diese verzögerten Daten etwa vorrangig vor Daten aus den höheren Prioritätsklasse übertragen würden. Soweit ersichtlich, werden sie aufgrund der FIFO-Eigenschaft der *Low priority egress queue* bei der nächsten Übertragungsrunde lediglich vorrangig vor den neu hinzukommenden Daten der *BE queue* bedient.

Vor diesem Hintergrund vermag die Kammer jedenfalls eine Offenbarung der Merkmalsgruppe f nicht mit hinreichender Sicherheit zu erkennen. Es mag zwar sein, dass es bei der Vorgehensweise aus der Entgegenhaltung NK 4 dazu kommen kann, dass bei Beginn einer neuen Übertragung verzögerte Daten in der *High* und der *Medium priority egress queue* anstehen, die bei der letzten Übertragungsrunde nicht zum Zuge kamen, und die den Umfang der Daten aus diesen beiden Prioritätsklassen im Ausgangsspeicher bestimmen. Dies ist etwa dann der Fall, wenn die Menge der verzögerten Daten und der neuen Daten aus der *EF queue* geringer ist als die maximale Datenrate, da in diesem Fall die Menge der verzögerten Daten die Menge der Daten aus der *EF queue* im Ausgangsspeicher beeinflusst, wobei hierüber dann auch die Menge der Daten aus den *AF queues* im Ausgangsspeicher beeinflusst würde, da diese die ungenutzte Bandbreite der *EF queue* nutzen können. Die Beklagte zeigt jedoch nicht auf, dass diese Konstellation in der Entgegenhaltung irgendwo beschrieben würde. Dass ein Fachmann dieses Zusammenwirken als unmittelbar und eindeutig zur in NK 4 geschilderten Lehre gehörend mitlesen würde, vermag die nicht sachkundige Kammer nicht mit der notwendigen Wahrscheinlichkeit feststellen

e) Soweit die Beklagte mit Blick auf die weiteren Rechtsbestandsangriffe pauschal auf den übrigen Inhalt der Nichtigkeitsklage verweist, vermag dies die Kammer ebenfalls

nicht zu einer Aussetzung zu veranlassen. Es entspricht der ständigen Praxis der Kammer, solche pauschalen Verweise auf eine vorgelegte Nichtigkeitsklage nicht genügen zu lassen, um eine Aussetzung zu begründen. Es obliegt nämlich der Beklagtenseite, durch substantiierten Vortrag diejenigen Aspekte aufzuzeigen, die die Prognose rechtfertigen, dass das Klagepatent mit hinreichender Wahrscheinlichkeit vernichtet werden wird. Demgegenüber ist es nicht Aufgabe der Kammer, gleichsam von Amts wegen eine vorgelegte Nichtigkeitsklage umfassen selbst zu prüfen und damit die Aufgabe wahrzunehmen, die den zur Entscheidung über den Rechtsbestand berufenen Instanzen zugewiesen ist.

VI.

Die Nebenentscheidungen folgen aus §§ 92 Abs. 2 Nr. 1, 709 S. 1 und S. 2 ZPO. Soweit die Beklagte Vollstreckungsschutz beantragt hat, war ihr dieser nicht zu gewähren. Die Beklagten hat nicht hinreichend dargetan, dass ihr die Vollstreckung der Unterlassungs-, Rückruf- und Vernichtungsansprüche einen nicht zu ersetzenden Nachteil bringen würde. Die Beklagte ist durch die festgesetzten Sicherheiten, die sich im Einklang mit dem Streitwert befinden, angemessen geschützt.

Verkündet am 25.11.2016

Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle